

제9절 유언

제1관 유언의 의의와 유언의 방식

1. 유언의 의의

유언을 한 사람이 사망한 후에야 유언한 대로 법률상 효력이 생기게 하는 법률행위를 유언이라 한다. 유언은 법률에서 정하는 특정한 방식을 필요로 하기 때문에 유언으로 정할 수 있는 사항은 법률에 정한 것에 한한다.

2. 유언의 법률적 성질

가. 요식행위이다

유언은 일정한 방식에 따를 것을 규정하고 있다. 유언의 요식성을 필수요건으로 하는 것은 유언자에게 신중하게 의사표시를 시키고, 유언자의 진의를 명확하게 확보하여 유언자의 사망 후, 즉 유언이 효력을 발생한 후의 유증을 받을 사람 그 밖의 이해관계인 사이의 유언내용에 관한 분쟁을 피하는 한편, 다른 사람의 위조·변조를 방지하기 위한 것이다. 따라서 민법이 정한 방식에 따르지 않는 유언은 무효가 된다. 이와 같이 민법 제1065조 내지 제1070조가 유언의 방식을 엄격하게 규정한 것은 유언자의 진의를 명확히 하고 그로 인한 법적 분쟁과 혼란을 예방하기 위한 것이므로, 법정된 요건과 방식에 어긋난 유언은 그것이 유언자의 진정한 의사에 합치하더라도 무효라고 하지 않을 수 없다.⁴⁵⁴⁾

나. 상대방이 없는 단독행위이다

유증을 받을 사람의 승낙은 물론, 그에 대한 의사표시를 하는 것도 필요 없다. 사인증여에는 유증에 관한 규정이 준용 되지만(민법 제562조), 사인증여는 성질상계약이며 유언처럼 단독행위가 아니라는 점에서 유증과 구별된다.

민법 제562조는 사인증여에 관하여는 유증에 관한 규정을 준용하도록 규정하고 있지만, 유증의 방식에 관한 민법 제1065조 내지 제1072조는 그것이 단독행위임을 전제로 하는 것이어서 계약인 사인증여에는 적용되지 아니한다.⁴⁵⁵⁾

454) 대법원 2006. 03. 09. 선고 2005다57899 판결; 대법원 1999. 09. 03. 선고 98다17800 판결.

상속재산의 분할 후 인지 또는 재판의 확정에 의하여 공동상속인이 된 자가 있는 경우라도 이미 분할을 한 다른 공동상속인은 상속재산 자체의 소유권을 확정적으로 취득하게 되고, 그 상속재산으로부터 발생하는 과실을 취득할 권능을 보유하게 되어, 공동상속인들이 취득한 그 과실은 ‘법률상 원인 없이’ 취득한 것이 아닌 게 되므로, 결국 상속재산의 과실에 대하여 분할 후 피인지자에게 그 회복을 허용하는 별도의 규정이 없는 이상, 분할 후 피인지자는 상속재산의 과실을 부당이득으로 반환청구 할 수는 없다.⁴⁵¹⁾

상속개시 후에 인지되거나 재판이 확정되어 공동상속인이 된 자도 그 상속재산이 아직 분할되거나 처분되지 아니한 경우에는 당연히 다른 공동상속인들과 함께 분할에 참여할 수 있을 것인바, 민법 제1014조는 그와 같은 인지 이전에 다른 공동상속인이 이미 상속재산을 분할 기타의 방법으로 처분한 경우에는 사후의 피인지자는 다른 공동상속인들의 분할 기타 처분의 효력을 부인하지 못하게 하는 대신, 이들에게 그 상속분에 상당한 가액의 지급을 청구할 수 있도록 하여 상속재산의 새로운 분할에 갈음하는 권리를 인정함으로써 피인지자의 이익과 기존의 권리관계를 합리적으로 조정하는 데 그 목적이 있다 할 것이고, 따라서 그 가액의 범위에 관하여는 부당이득반환의 범위에 관한 민법규정을 유추적용 할 수 없고, 다른 공동상속인들이 분할 기타의 처분 시에 피인지자의 존재를 알았는지의 여부에 의하여 그 지급할 가액의 범위가 달라지는 것도 아니다.⁴⁵²⁾

(다) 상속재산의 처분에 의한 조세부담을 민법 제1014조의 가액에서 공제할 것인지

상속재산의 처분에 수반되는 조세부담은 상속에 따른 비용이라고 할 수 없고 민법 제1014조에 의한 가액의 지급청구는 상속재산이 분할되지 아니한 상태를 가정하여 피인지자의 상속분에 상당하는 가액을 보장하려는 것이므로, 다른 공동상속인들의 분할 기타의 처분에 의한 조세부담을 피인지자에게 지급할 가액에서 공제할 수 없고, 다른 상속인들이 피인지자에게 그 금액의 상환을 구할 수도 없다.⁴⁵³⁾ 그러나 상속세 부담은 공제하여야 한다.

451) 서울중앙지방법원 2005. 06. 14. 선고 2004가합98799 판결: 항소.

452) 대법원 1993. 08. 24. 선고 93다12 판결.

453) 대법원 1993. 08. 24. 선고 93다12 판결.

다. 반드시 유언자 본인의 독립된 의사에 의하여 이루어져야 하는 행위이다

유언제도는 사람의 최종의사를 존중하고 그것에 법률효과를 부여하는 것이기 때문에, 유언은 반드시 유언자 본인의 독립된 의사에 기초하여 이루어지지 않으면 안 된다. 따라서 대리유언은 허용되지 않으며, 제한능력자의 유언이라 할지라도 법정대리인의 동의는 필요 없다.

라. 유언자가 언제든지 철회할 수 있다

유언의 철회를 자유롭게 하는 것은 유언은 종의처분(終意處分)이며, 이러한 유언자의 최종의사를 존중하기 위한 것이다.

마. 사후행위이다

유언은 유언한 사람의 사망으로 인하여 효력이 발생한다. 그러므로 유언에 의한 수익자는 유언의 효력이 발생되기까지는 아무런 법률상의권리(조건부권리)도 취득하지 않는다. 따라서 유언자가 유증의 목적인 부동산을 유증 받을 사람 이외의 사람에게 매각 등 처분하는 것은 방해받지 않는다.

바. 법정사항에 한하여 할 수 있는 행위이다

법정사항 이외의 사항, 예컨대 도덕적 의미를 가진 유훈(遺訓) 같은 것은 민법상의 유언이 아니며, 따라서 유언서에 기재하더라도 유언으로서는 법률상 무효이다.

사. 유언은 그 내용에 따라 법정상속분을 변경하는 힘을 갖는다

재산에 관한 유언을 하게 되면 법정상속분에 의하지 않고 그 유언의 내용에 따라 상속재산을 분배받게 된다. 그래서 유언하는 사람이 법정상속분에 따른 상속재산의 분배를 원하지 않는 경우에는 사망하기 전에 유언을 통하여 그의 소망을 이루어지게 할 수 있다. 다만, 이러한 유증을 하는 데는 다음에 설명하는 유류분(민법 제1112조 내지 제1118조) 규정에 의한 제한을 받게 된다.

455) 대법원 2001. 09. 14. 선고 2000다66430, 66447 판결.

3. 유언사항

가. 민법규정

유언의 내용으로 할 수 있는 사항은 무제한이 아니고 특히 법률이 규정하는 사항에 한한다. 따라서 법률에 규정되지 않은 사항에 관한 유언은 법률상 효력을 발생할 수 없다. 민법이 유언으로서의 효력을 인정하고 있는 이른바 유언사항은 다음과 같다.

나. 생전행위나 유언으로도 할 수 있는 사항

- (1) 재단법인의 설립을 위한 출연행위(민법 제47조2항)
- (2) 친생부인(민법 제850조)
- (3) 인지(민법 제859조 제2항)
- (4) 유증(민법 제1074조 이하)
- (5) 신탁의 설정(신탁법 제2조)

다. 유언에 의해서만 할 수 있는 사항

- (1) 후견인 지정(민법 제931조)
- (2) 상속재산분할방법의 지정 또는 위탁(민법 제1012조 전단)
- (3) 상속재산분할금지(민법 제1012조 후단)
- (4) 유언집행자의 지정 또는 위탁(민법 제1093조)

4. 유언능력

만 17세에 달하지 못한 자는 유언을 하지 못한다(민법 제1061조). 따라서 만 17세 이상의 사람은 유언을 할 수 있다. 그러나 만 17세 이상이라도 의사능력은 있어야 한다. 그러므로 17세 이상 제한능력자라고 할지라도 의사능력만 있으면 법정대리인의 동의를 필요로 하지 않고 독자적으로 유언을 할 수 있다. 피한정후견인도 한정후견인의 동의 없이 모든 유언사항에 관하여 유언할 수 있고, 후견인의 동의가 없는 유언이라 하여 취소하지 못한다. 피성년후견인도 성년후견인의 동의 없이 유언을 할 수 있지만, 의사가 심신회복상태를 유언서에 부기하고 서명·날인하여야 한다(민법 제1063조). 위와 같은 유언능력의 취지를 명확하게 하기 위하여, 민법은 유언능력에 있어서는 미성년자에 관한 제5조, 피성년후견인에 관한 제10조, 피한정후견인에 관한 제13조의 규정은 적용하지 않는 것으로 하고 있다

(민법 제1062조).

5. 유언능력 존재 시기

유언은 그 성립의 시기와 효력발생의 시기 사이에 시간적 간격이 있는 것이 보통이다. 따라서 유언능력에 대하여는 유언성립 시에만 존재하면 되느냐 또는 유언의 효력발생 시(사망 시)에도 능력자이어야 하느냐가 문제이다. 그런데 이 문제는 유언의 의사표시를 한 때를 기초를 하여 그 유무를 결정하는 것이 타당하다고 본다.⁴⁵⁶⁾ 왜냐하면, 유언은 유언자의 사망 시에 그 효력이 확정되기는 하지만, 일단 유언을 한 후에 그 유언을 철회할 수 있다는 점(민법 제1108조), 그리고 취소하지 않는 한 그 유언은 효력일 있다는 점은 유언이 의사표시를 한 때에 성립하는 것을 시사하는 것이기 때문이다. 따라서 유언 당시에 유언능력을 가진 사람이 한 유언은 후에 유언자가 심신상실 등의 이유로 사망 당시에 제한능력자가 된다 하더라도 그 효력은 변하지 않는다. 반대로 제한능력자가 한 유언은 후에 유언자가 유언 능력자가 되거나 그 유언을 추인하더라도 효력이 발생하지 않는다.

6. 유언의 방식

가. 의 의

앞서 말한 바와 같이 유언능력이 있다 하여 자유로이 유언을 할 수 있는가? 그렇지 않다. 유언을 하려면 법이 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생기지 아니한다. 따라서 반드시 법이 규정한 5가지 방식 중 하나를 선택하여 유언을 하여야 한다. 민법 제1065조 내지 제1070조가 유언의 방식을 엄격하게 규정한 것은 유언자의 진의를 명확히 하고 그로 인한 법적 분쟁과 혼란을 예방하기 위한 것이므로, 법정된 요건과 방식에 어긋난 유언은 그것이 유언자의 진정한 의사에 합치하더라도 무효이다. 이처럼 유언의 방식은 매우 엄격하다. 유언에 관하여 엄격한 방식을 요구하는 이유는 유언자의 진의의 확보를 위해서이다. 민법이 규정한 유언의 방식을 살펴보면 다음과 같다.

나. 자필증서에 의한 유언

(1) 의 의

유언자가 유언의 전문·작성 연월일·주소·성명을 자서하고 날인함으로써 성립하는

456) 법원행정처, 『상속등기실무』, 229면.

유언이다(민법 제1066조 제1항). 이는 증인이 필요 없는 유일한 유언의 방식이다. 자필증서에 대한 유언은 문자를 알고 또한 쓸 줄 아는 사람이면 누구나 간편하게, 또한 비용도 들지 않는 장점이 있다. 반면에 문자를 모르는 사람은 쓸 수 없다는 점, 유언증서의 유무가 유언자의 사후에 쉽게 판명되지 않는 점, 또한 분실·멸실 할 염려, 위조·변조의 위험이 많다는 단점이 있다.

[서식] 자필증서에 의한 유언서의 예

유 언 서

유언자 ○○○은 아래와 같이 유언을 한다.

1. 유언자 ○○○은 나의 소유 부동산인 서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○, 201동 1203호(○○동, ○○아파트)를 ○○○에게 증여한다.
2. 유언자 ○○○은 나의 소유인 예금증서(○○은행, 계좌번호○○○○ - ○○○ - ○○○정기예금)를 ○○○에게 증여한다.
3. 유언자 ○○○은 나의 소유인 임야 1,000제곱미터(○○시 ○○구 ○○동 2-3)를 ○○○고아원에 증여한다.
4. 서울 ○○구 ○○동 3, 1995년 5월 23일생 ○○○을 인지한다.
5. 유언자는 아래 사람을 유언집행자로 지정한다.

성명 : ○○○

주소 : 서울 ○○구 ○○동 6

위 유언서는 유언자 스스로 그 전문을 쓰고 날짜, 성명을 자필하고 날인하였다.

20○○. 8. 25.

유언자 ○ ○ ○ (인)

주민등록번호 :

서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○

[서식] 자필증서에 의한 유언서의 예

유언증서

유언자 김 ○ 수

19○○년 ○월 ○일생

등록기준지 ○○시 ○○구 ○○대로 ○○

주 소 서울 ○○구 ○○대로○○길 ○○(○○동)

전 화 ○○○ - ○○○○

유언사항

나는 다음과 같이 유언한다.

1. 재산의 사인증여⁴⁵⁷⁾(또는 유증⁴⁵⁸⁾)에 관하여,

(1) ○○시 ○○동 123 대 ○제곱미터는 이를 상속인 중 장남 김○준(주소:

생년월일:)에게 증여하고,

(2) ○○시 ○○동 123-4(○○대로 10) 대 ○○제곱미터 및 지상 철근 콘크리트

조 슬라브지붕 1층 주택 ○○제곱미터는 차남 김○구(주소: , 생년월일:

)에게 증여하며, 이 사인증여(또는 유증)는 나의 사망으로 인하여 효력

이 발생한다.

2. 유언집행자의 지정에 관하여

위 사인증여(또는 유증)의 이행을 위하여 유언집행자로 양○수(주소: , 주민등

록번호:)를 지정한다.

작성일자 서기 20○○년 ○월 ○일

유언자 성명 김 ○ 수 (인)

457) 민법 제562조 계약이며, 등기원인은 “증여”가 된다.

458) 민법 제1073조 단독행위이며, 등기원인은 “유증”이 된다.

(2) 요 건

(가) 전문자서

전문의 자서는 반드시 유언자가 써야 하며 남에게 대신 쓰게 하거나, 타이프로 친다든지 전자복사기를 이용하여 작성한 복사본은 무효이다. 사용하는 문자는 제한이 없다. 필기도 구나 용지도 제한이 없다. 다만, 연필로 쓴 것은 지워지기 쉽고 고치기가 쉬워서 사용하지 않는 것이 바람직하다.

(나) 작성연월일의 자서

유언을 한 연월일은 정확히 기재하여야 한다. 연월일을 기재한 이유는 유언의 성립시기를 명확히 하기 위해서이고, 또한 저촉하는 복수의 유언서가 있는 경우 그 우열을 판단하는 기준이 되기 때문이다. 따라서 작성연월일이 없는 유언서는 무효라고 본다. 그러므로 연과 월만 적고 일의 기재가 없는 것도 무효이다.⁴⁵⁹⁾ 그러나 제 몇 회 생일에, 回甲日, 古稀祝賀日, 銀婚日 등과 같이 외부적 사항에 비추어 확정될 수 있는 경우라면 유효하다.

연월일의 자서가 2개 이상 있는 경우는 나중의 일자를 기준으로 하는 것이 타당하다. 또한 연월일의 기재위치에 관한 특별요건이 없으므로 유언서의 본문에 자서뿐만 아니라 유언서를 봉투에 넣고 봉인하여 그 봉투에 연월일을 기재해도 상관없다고 본다.

(다) 주소와 성명의 자서

자서하여야 할 주소는 유언서의 작성지가 아니라 유언자의 주소이다. 주소는 주민등록법에 의하여 등록한 곳이 아니더라도 생활의 근거가 되는 곳이면 된다. 성명은 그 유언자가 누구의 것인가를 알 수 있을 정도면 된다. 따라서 본명, 통칭 등 어느 것으로 사용해도 유효하다.

민법 제1065조 내지 제1070조가 유언의 방식을 엄격하게 규정한 것은 유언자의 진의를 명확히 하고 그로 인한 법적 분쟁과 혼란을 예방하기 위한 것이므로, 법정된 요건과 방식에 어긋난 유언은 그것이 유언자의 진정한 의사에 합치하더라도 무효이다. 따라서 자필증서에 의한 유언은 민법 제1066조 제1항의 규정에 따라 유언자가 전문과 연월일, 주소, 성명을 모두 자서하고 날인하여야만 효력이 있고, 유언자가 주소를 자서하지 않았다면 이는 법정된 요건과 방식에 어긋난 유언으로서 효력을 부정하지 않을 수 없으며, 유언자의 특징에 지장이 없다고 하여 달리 볼 수 없다. 여기서 자서가 필요한 주소는 반드시 주민등록법에

459) 대법원 2009. 05. 14. 선고 2009다9768 판결.

의하여 등록된 곳일 필요는 없으나, 적어도 민법 제18조에서 정한 생활의 근거되는 곳으로서 다른 장소와 구별되는 정도의 표시를 갖추어야 한다.⁴⁶⁰⁾

자필증서에 의한 유언은 유언자가 그 전문과 연월일, 주소, 성명을 자서(自書)하고 날인하여야 하는바(민법 제1066조 제1항), 유언자의 주소는 반드시 유언 전문과 동일한 지면에 기재하여야 하는 것은 아니고, 유언증서로서 일체성이 인정되는 이상 그 전문을 담은 봉투에 기재하더라도 무방하며, 그 날인은 무인에 의한 경우에도 유효하고, 유언증서에 문자의 삽입, 삭제 또는 변경을 함에는 유언자가 이를 자서하고 날인하여야 하나(민법 제1066조 제2항), 증서의 기재 자체로 보아 명백한 오기를 정정함에 지나지 아니하는 경우에는 그 정정 부분에 날인을 하지 않았다고 하더라도 그 효력에는 영향이 없다.⁴⁶¹⁾

유언증서가 요식의 가장 중요한 처분증서의 하나라 하더라도 일반인의 거래관청이나 문서작성의 실정 및 규범의식에 비추어 자필증서에 의한 유언의 경우 전문과 연월일, 성명의 자서와 날인 중 어느 한 가지를 누락하는 경우와는 달리 주소까지 기재해야만 유언의 효력이 발생한다고 보는 것은 비현실적일 뿐만 아니라 실제적으로도 필요 이상의 엄격한 제한을 가하여 유언자의 진정한 유지를 실현시키지 못하는 부당한 결과를 초래할 가능성도 있으므로, 다른 요건을 모두 갖추고 단지 주소의 기재만을 빠뜨린 경우에는 유언 방식의 엄격성을 요구하는 법의 취지는 달성되었다고 보아야 하고, 따라서 유언의 효력을 부정할 수 없다.⁴⁶²⁾

갑이 자녀 중 을이 자신 명의의 모든 재산을 상속한다는 내용의 유언장을 작성하였는데, 갑의 다른 자녀인 병 등이 유언장의 주소 기재 부분이 법정 요건을 갖추지 않아 효력이 없다고 주장한 사안에서, 자필증서에 의한 유언은 민법 제1066조 제1항에 따라 유언자가 전문과 연월일, 주소, 성명을 모두 자서하고 날인하여야만 효력이 있고, 유언자가 주소를 자서하지 않았다면 법정된 요건과 방식에 어긋난 유언으로서 효력을 부정하지 않을 수 없으며, 유언자의 특징에 지장이 없다고 하여 달리 볼 수 없고, 여기서 자서가 필요한 주소는 반드시 주민등록법에 의하여 등록된 곳일 필요는 없으나, 적어도 민법 제18조에서 정한 생활의 근거되는 곳으로서 다른 장소와 구별되는 정도의 표시를 갖추어야 하는데, 갑이 유언장에 기재한 주소가 주민등록상으로는 존재하지 않으나 유언장 작성 당시 갑의 주민등록상 주소와 가지번호를 제외하고는 동일한 점 등에 비추어 보면 다른 장소와 구별되는 정도의 표시를 갖춘 생활의 근거되는 곳을 기재한 것으로 볼 수 있어, 유언장의 주소 기재

460) 대법원 2014. 9. 26. 선고 2012다71688 판결.

461) 대법원 1998. 05. 29. 선고 97다38503 판결.

462) 인천지방법원 1992. 10. 09. 선고 91가합17999 판결.

부분이 법정 요건을 갖추었다.⁴⁶³⁾

(라) 날 인

유언의 방식 및 효력 등에 관한 민법의 형식적 엄격주의 및 자필증서에 의한 유언의 특성 등을 고려해 볼 때 자필증서에 의한 유언에 있어서 성명의 자서가 되어 있지 아니한 경우뿐만 아니라 날인이 누락되어 있는 경우에도 적법한 유언으로서의 효력은 없다.⁴⁶⁴⁾

유언자가 날인하여야 할 문서는 문서의 원본이지 복사본에 날인하는 것은 자필증서에 의한 유언으로 유효하지 않다. 유언자가 상속인들에게 작성·교부한 유언증서가 유언으로서의 법적 방식에 맞지 않아 무효라 할지라도, 그 증서에 자신이 사망하는 경우 특정한 재산을 위 상속인들에게 증여한다는 내용이 포함되어 있고 이에 위 상속인들이 동의한 경우에는 유언자와 위 상속인들 사이에 유효한 사인증여계약이 성립하므로, 위 유언증서는 사인증여계약으로서 효력이 있다.⁴⁶⁵⁾ 날인은 유언자의 인감도장이든 막도장이든 무인⁴⁶⁶⁾이든 상관없다.

그러나 유언자의 것임이 인정되지 않는 무인이 찍혀 있고, 유언증서 자체에 유언자의 주소가 자서되어 있지 아니한 유언증서에 대하여, 자필증서에 의한 유언의 효력이 인정되지 않는다.⁴⁶⁷⁾

(3) 유언내용의 삽입·삭제·변경

유언자가 유언의 전문을 쓰다가 문자의 삽입, 삭제 또는 변경을 할 경우 유언자가 이를 자서하고 날인하여야 한다(민법 제1066조 제2항). 자필증서에 의한 유언에 있어서 그 증서에 문자의 삽입, 삭제 또는 변경을 함에는 민법 제1066조 제2항의 규정에 따라 유언자가 이를 자서하고 날인하여야 하나, 자필증서 중 증서의 기재 자체에 의하더라도 명백한 오기를 정정한 것에 지나지 않는다면 설령 그 수정 방식이 위 법조항에 위배된다고 할지라도 유언자의 의사를 용이하게 확인할 수 있으므로 이러한 방식의 위배는 유언의 효력에 영향을 미치지 아니한다.⁴⁶⁸⁾

463) 대구고등법원 2016. 6. 1. 선고 2015나22565 판결 : 상고(취하).

464) 서울중앙지방법원 2005. 07. 05. 선고 2003가합86119, 89828 판결; 대법원 2006. 09. 08. 선고 2006다25103 판결.

465) 제주지방법원 2008. 04. 23. 선고 2007가단22957, 27419 판결: 확정.

466) 대법원 1998. 06. 12. 선고 97다38510 판결; 대법원 1998. 05. 29. 선고 97다38503 판결.

467) 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006다12848 판결.

468) 대법원 1998. 05. 29. 선고 97다38503 판결; 대법원 1998. 06. 12. 선고 97다38510 판결.

다. 녹음에 의한 유언

(1) 의 의

유언자가 유언의 취지, 그 성명과 연월일을 말하고 이에 참여한 증인이 유언의 정확함과 그 성명을 말함으로써 성립한다(민법 제1067조).

녹음에 의한 유언은 증인이 필요하며, 유언자의 육성을 사후에도 보존할 수 있다는 점과 녹음기만 있으면 간편하게 유언할 수 있는 장점이 있지만 녹음된 것이 지워져 버릴 수 있다는 단점이 있다.

(2) 요 건

(가) 녹 음

녹음은 음성을 음반·테이프·필름 등에 기록하는 것이다. 어느 방법에 의하든 상관없다. 따라서 유언의 취지와 그 성명과 연월일을 구술한다.

(나) 증 인

참여한 증인이 유언의 정확함과 그 성명을 구술한다. 이처럼 녹음에 의한 유언은 반드시 증인이 참여하여야 한다. 누구를 증인으로 하느냐는 유언자가 결정하게 되며, 유언자의 요청을 받아 수락한 자가 증인으로서 유언작성에 참여하게 된다. 즉, 미성년자, 피성년후견인, 피한정후견인, 유언에 의하여 이익을 받을 자 및 그 배우자와 직계혈족에 해당하는 자는 유언에 참여하는 증인이 되지 못한다(민법 제1072조). 증인의 수에 대하여 제한이 없으므로 1명 이상 증인이 참여하여 구술하면 충분하다.⁴⁶⁹⁾

공정증서에 의한 유언에 있어서는 2인 이상의 증인이 참여하여야 하는데, 유언에 참여할 수 없는 증인결격자의 하나로 민법 제1072조 제1항 제3호가 규정하고 있는 ‘유언에 의하여 이익을 받을 자’라 함은 유언자의 상속인으로 될 자 또는 유증을 받게 될 수증자 등을 말하는 것이므로, 유언집행자는 증인결격자에 해당한다고 볼 수 없다.⁴⁷⁰⁾

또한 공정증서에 의한 유언의 경우 공증인법(제33조⁴⁷¹⁾ 제3항)에 의한 결격자는 증인

469) 법원행정처, 『상속등기실무』, 236면.

470) 대법원 1999. 11. 26. 선고 97다57733 판결.

471) 공증인법 제33조 ① 통역인과 참여인은 촉탁이나 또는 그 대리인이 이를 선정하여야 한다.

② 참여인은 통역인을 겸할 수 있다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 참여인이 될 수 없다. 다만, 제29조제2항에 따라 촉탁인이 참여인의 참여를 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.

이 되지 못한다.

민법 제1072조는 제1항에서 일반적으로 유언에 참여하는 증인이 될 수 없는 자를 열거하는 외에, 제2항에서 공정증서에 의한 유언의 경우에는 공증인법에 의한 참여인 결격자는 증인이 되지 못한다고 따로 규정하고 있는바, 한편 공증인법 제33조 제3항은 본문에서 공증 시 참여인이 될 수 없는 자의 하나로 공증촉탁인의 친족을 들면서도 단서에서 ‘공증촉탁인이 공증에 참여시킬 것을 청구한 경우’에는 예외적으로 같은 법 제33조 제3항 본문 규정의 적용이 배제됨을 규정하고 있어, 결국 공증참여자가 유언자와 친족의 관계에 있다 하더라도 유언자의 청구에 의한 경우에는 공증인법에 의한 공증참여인 결격자가 아니라고 보아야 할 것이다.⁴⁷²⁾

(3) 녹음방법

주위가 조용한 곳에서 증인의 참여로 다음과 같이 녹음을 한다.

[예문] 녹음에 의한 유언의 예

(가) 유언자 녹음

유언자 ○○○은 2002. 3. 3. 현재 시각 오전 9시 30분부터 서울 ○○구 ○○대로 50에 주소를 둔 증인 ○○○를 참여시키고 유언하려고 한다.

먼저 유언자 ○○○의 인적사항으로 등록기준지는 서울 ○○구 ○○로 11이고, 생년월일은 1950. ○. ○.생이며, 주민등록번호는 501233-1234567이다. 그리고 주소는 서울 ○○구 ○○로 10, 101동 101호(○○동, ○○아파트)이며, 나의 재산을 다음과 같이 유언을 한다.

첫째, 서울 ○○구 ○○로 10, 101동 101호(○○동, ○○아파트)는 처 ○○○의 소유로 유증을 하고,

1. 미성년자
2. 시각장애인이거나 문자를 해독하지 못하는 사람
3. 서명할 수 없는 사람
4. 촉탁 사항에 관하여 이해관계가 있는 사람
5. 촉탁 사항에 관하여 대리인 또는 보조인이거나 대리인 또는 보조인이었던 사람
6. 공증인의 친족, 피고용인 또는 동거인
7. 공증인의 보조자

472) 대법원 1992. 3. 10. 선고 91다45509 판결

둘째, 서울 ○○구 ○○동 123 대 1,000제곱미터 중 600제곱미터 및 ○○회사주식 5,000주를 장남 ○○○의 소유로 유증하고,

셋째, 서울 ○○구 ○○동 123 대 1,000제곱미터 중 400제곱미터 및 ○○은행 예금 7,000만 원 중 5,000만 원을 차남 ○○○의 소유로 하며,

넷째, 출가한 딸 ○○○은 서울 ○○구 ○○로 20, 102동 102호(○○동, ○○아파트)와 ○○은행 예금 7,000만 원 중 2,000만 원을 유증한다.

다섯째, 유언집행자는 서울 ○○구 ○○로 30에 주소를 둔 ○○○를 지정한다.

이상과 같이 거짓 없이 진실로 녹음을 한다.

20○○. 3. 3. 현재 시각 오전 10시 서울 ○○구 ○○로 10, 101동 101호(○○동, ○○아파트) 자택에서 유언자 ○○○

(나) 유언자가 녹음한 후 바로 증인의 확인녹음을 한다.

서울 ○○구 ○○로 10에 주소를 두고 주민등록번호가 610123-1234567인 증인 ○○○은 주민등록번호가 501233-1234568이고, 서울 ○○구 ○○로 20에 주소를 둔 유언자 ○○○이 위와 같이 녹음에 의하여 유언하는데 20○○. 3. 3. 오전 9시 30분부터 오전 10시까지 증인으로 참여하였으며, 위 녹음에 의한 유언내용이 진실임을 확인한다.

20○○. 3. 3. 현재 시각 오전 10시 10분. 증인 ○○○

라. 공정증서에 의한 유언

(1) 의 의

유언자가 증인 2인이 참여한 공증인의 면전에서 증언의 취지를 말하고 공증인이 이를 필기 낭독하여 유언자와 증인이 그 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인함으로써 성립한다(민법 제1068조). 공정증서에 의한 유언의 방식은 유언의 존재를 명확히 하고 그 내용을 확고히 할 수 있는 특징이 있으며 유언의 확실을 기하는 점에서 유용하지만 비밀을 확보하기 어렵다는 것이다.

공정증서가 아닌 유언서는 유언자의 사망 후 즉시 법원의 검인을 받아야 하나, 공정증서에 의한 유언의 경우에는 그와 같은 절차가 생략되어 편리한 장점은 있다.

(2) 요 건

(가) 증인 2인의 참여가 있어야 한다.

증인에 대하여는 앞에서 설명한 ‘녹음에 의한 유언’(409면)을 참조한다.

망인이 1991. 4. 10. “망인은 1991. 4. 9. 이 사건 부동산을 피고 1에게만 유증한다.”는 내용으로 타자된 유언장에 대하여 공증사무실에서 인증을 받은 사실이 인정되나, 위 유언장은 증인 2명의 참여가 없고 자서된 것도 아니어서 공정증서에 의한 유언이나 자필증서에 의한 유언으로서의 방식이 결여되어 있으므로 유언으로서의 효력을 발생할 수 없다.⁴⁷³⁾

(나) 유언자는 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하여야 한다.

구수는 입으로 말을 해서 상대방에게 전하여 그것을 기억하는 것이다. ‘유언취지의 구수’라 함은 말로써 유언의 내용을 상대방에게 전달하는 것을 뜻하므로 이를 엄격하게 제한하여 해석하여야 할 것이지만, 공증인이 유언자의 의사에 따라 유언의 취지를 작성하고 그 서면에 따라 유언자에게 질문을 하여 유언자의 진의를 확인한 다음 유언자에게 필기된 서면을 낭독하여 주었고, 유언자가 유언의 취지를 정확히 이해할 의사식별능력이 있고 유언의 내용이나 유언 경위로 보아 유언 자체가 유언자의 진정한 의사에 기한 것으로 인정할 수 있는 경우에는, 위와 같은 ‘유언취지의 구수’ 요건을 갖추었다고 보아야 한다.⁴⁷⁴⁾

유언공정증서를 작성할 당시에 유언자가 반혼수 상태였으며, 유언공정증서의 취지가 낭독된 후에도 그에 대하여 전혀 응답하는 말을 하지 아니한 채 고개만 끄덕였다면, 유언공

473) 대법원 1994. 12. 22. 선고 94다13695 판결.

474) 대법원 2007. 10. 25. 선고 2007다51550, 51567 판결; 대법원 2008. 8. 11. 선고 2008다1712 판결.

정증서를 작성할 당시에 유언자에게는 의사능력이 없었으며 그 공정증서에 의한 유언은 유언자가 유언의 취지를 구수(口授)하고 이에 기하여 공정증서가 작성된 것으로 볼 수 없어서, 민법 제1068조가 정하는 공정증서에 의한 유언의 방식에 위배되어 무효이다.⁴⁷⁵⁾

공정증서에 의한 유언은 유언자가 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하여 작성되어야 하는 것이므로 뇌혈전증으로 병원에 입원치료 중인 유언자가 불완전한 의식상태와 언어장애 때문에 말을 못하고 고개만 끄덕거리면서 반응을 할 수 있을 뿐인 의학상 소위 가면성 정신상태하에서 공증인이 유언내용의 취지를 유언자에게 말하여 주고 ‘그렇소?’ 하고 물으면 유언자는 말은 하지 않고 고개만 끄덕거리면 공증인의 사무원이 그 내용을 필기하고 이를 공증인이 낭독하는 방법으로 유언서가 작성되었다면 이는 유언자가 구수한 것이라고 할 수 없으므로 무효이다.⁴⁷⁶⁾

제3자에 의하여 미리 작성된 유언의 취지가 적혀 있는 서면에 따라 유언자에게 질문을 하고 유언자가 동작이나 한두 마디의 간략한 답변으로 긍정하는 경우에는 원칙적으로 민법 제1068조에 정한 ‘유언취지의 구수’라고 보기 어렵지만, 공증인이 사전에 전달받은 유언자의 의사에 따라 유언의 취지를 작성한 다음 그 서면에 따라 유증 대상과 수증자에 관하여 유언자에게 질문을 하고 이에 대하여 유언자가 한 답변을 통하여 유언자의 의사를 구체적으로 확인할 수 있어 그 답변이 실질적으로 유언의 취지를 진술한 것이나 마찬가지로 볼 수 있고, 유언자의 의사능력이나 유언의 내용, 유언의 전체 경위 등으로 보아 그 답변을 통하여 인정되는 유언취지가 유언자의 진정한 의사에 기한 것으로 인정할 수 있는 경우에는, 유언취지의 구수 요건을 갖추었다고 볼 수 있다.⁴⁷⁷⁾

(다) 공증인이 유언자의 구수를 필기하여 이것을 유언자가 증인 앞에서 낭독할 것 필기는 공증인 자신이 반드시 할 필요는 없으며, 보조자에게 필기시켜도 상관없다. 또 공증인이 미리 유언자가 작성한 문안을 받고 유언자가 구수하는 것을 들은 다음 이것으로써 필기에 갈음하는 것과 같이 구술과 필기가 바뀌어도 상관없다고 한다.⁴⁷⁸⁾ 공정증서는 국어로 작성되어야 한다(공증인법 제26조).

(라) 유언자와 증인이 필기가 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인할 것
공증인은 그 사무소에서 직무를 행하는 것이 원칙(공증인법 제17조 제2항) 유언의 경우

475) 대법원 1996. 04. 23. 선고 95다34514 판결.

476) 대법원 1980. 12. 23. 선고 80므18 판결.

477) 대법원 2008. 02. 28. 선고 2005다75019, 75026 판결.

478) 김주수, 앞의 책, 617면; 박동섭, 앞의 책, 739면.

에는 적용이 없다(동법 제56조). 따라서 공정증서에 의한 유언을 작성할 경우에는 출장을 요구할 수 있다.

(마) 공증인이 부기하고 서명날인 할 것

(바) 공정증서에 의한 유언을 무효라고 한 사례

① 유언 당시 병원 중환자실에 입원 중이던 박○○이 의사전달능력은 있었으나 수술에 의하여 기관지가 절개된 상태였기 때문에 말을 하기 위해서는 절개 부분에 삽입된 의료기구를 제거하고 절개된 부분을 막아야만 쉼 목소리로 발음을 할 수 있었을 따름이고, 또 유언과 동시에 유언의 취지와 다소 모순되게 액면금 2억 원의 약속어음을 소송수계신청인에게 발행·교부하였다면, 과연 공정증서에 기재된 내용과 같이 제대로 된 유언의 구수가 있었는지에 관해서 강력한 의심이 들 뿐만 아니라, 가사 유언의 구수가 있었다고 하더라도, 위에서 본 바와 같이, 공증담당 변호사가 직무집행구역을 벗어나 구수를 받은 유언을 필기 낭독하고 유언자와 증인으로부터 그 정확성의 승인을 받은 후 공정증서에 서명 또는 기명 날인을 받는 절차를 생략한 채, 단지 유언공정증서를 이루는 말미용지에 서명·날인을 받았을 뿐이며, 그 서명 또한 박○○이 사지마비로 직접 서명할 수 없는 상태여서 다른 사람이 박○○의 손에 필기구를 쥐어주고 그 손을 잡고 같이 서명을 하였고, 이후 변호사가 서울에 있는 공증사무실에 돌아와 마치 자신의 사무실에서 유언이 있었고 그에 따른 필기 낭독과 정확성의 승인 및 서명날인 있었던 것처럼 공정증서를 작성한 것이라면, 앞서 본 요건 중, ‘공증인이 유언자의 구술을 필기해서 이를 유언자와 증인에게 낭독할 것’과 ‘유언자와 증인이 공증인의 필기가 정확함을 승인할 것’이라는 요건을 갖추지 못하였음은 분명하고, 나아가 다른 사람이 사지가 마비된 박○○의 손을 잡고 공정증서 말미용지에 서명과 날인을 하게 한 행위만으로는 박○○의 서명날인이 있다고 할 수도 없으므로, 위 요건 중 ‘유언자가 서명 또는 기명날인할 것’이라는 요건도 갖추지 못하였다 할 것이다. 그렇다면 이 사건 유언은 민법 제1068조가 정하는 공정증서에 의한 유언의 방식에 위배되어 무효이다.⁴⁷⁹⁾

② 공정증서에 증인으로 참석하여 서명, 날인한 것으로 기재되어 있는 송○○는 실제로 참여하거나, 서명, 날인한 바 없고, 또 변호사는 당시 자택에서 그가 구수하는 유언의 취지를 메모한 다음, 위 법률사무소의 사무실로 돌아와 그 메모를 기초로 이 사건 유언공정증서를 작성하였는데, 다시 그 기재 내용을 유언자에게 가서 낭독하여 그 정확함을 승인받는

479) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2000다21802 판결.

절차를 밟지 아니한 채, 유언자가 아닌 다른 사람이 가져온 유언자의 인장을 대신 날인한 사실 등을 각 인정한 다음, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 공정증서를 작성함에 있어 증인 2명이 참석하지 아니하였고, 필기한 유언의 취지를 유언자에게 낭독하여 그 정확함을 승인 받는 절차를 거친 후에 유언자의 기명날인이 이루어지지 아니하였으므로, 이 사건 공정증서에 의한 유언은 그 효력이 없다.⁴⁸⁰⁾

③ 유언공정증서를 작성할 당시에 유언자가 반혼수상태였으며, 유언공정증서의 취지가 낭독된 후에도 그에 대하여 전혀 응답하는 말을 하지 아니한 채 고개만 끄덕였다면, 유언공정증서를 작성할 당시에 유언자에게는 의사능력이 없었으며 그 공정증서에 의한 유언은 유언자가 유언의 취지를 구수(口授)하고 이에 기하여 공정증서가 작성된 것으로 볼 수 없어서, 민법 제1068조가 정하는 공정증서에 의한 유언의 방식에 위배되어 무효이다.⁴⁸¹⁾

④ 망 김○○가 평소 당뇨병 등의 판시 지병으로 치료를 받아 오던 중 19○○. 12. 26.경 토혈, 혈변증세가 나타나게 되어 ○대학교의과대학부속 ○병원에 입원하게 된 사실, 위 김○○는 병원에서의 치료로 토혈은 멎고 맑은 의식상태가 유지되는 등 같은 해 12. 29.까지는 상태가 다소 호전되는 듯하다가 같은 해 12. 30. 08:00경부터는 판시와 같은 병세가 악화되기 시작하여 다음날 00:20경부터는 몸에 부종이 생기고 의식혼란이 심하여졌으며 같은 날 11:00경에는 시간, 장소, 삶에 대한 분별력을 잃은 상태에서 큰소리로 부르면 겨우 반응하고 고통을 주면 약간 반응하는 정도의 언어반응 및 운동반응을 보이는 반혼수 상태에 있었던 사실, 위 김○○의 병세가 더 이상 호전되지 아니할 징후를 보이자 그의 가족의 연락으로 공증업무를 취급하는 변호사 임○○이 위 병원에 와서 그의 면전에서 증인 소외 송○○, 정○○의 참여 아래 같은 날 15:00경 위 김○○가 유언을 하게 되었는데, 위 변호사 임○○이 위 김○○에게 유언공증을 하러 왔다고 말하고 위 김○○의 재산상속에 관한 의사를 확인하기 위하여 그에게 재산을 어떻게 할 것이냐 그 전에 말한 대로 모든 재산을 3남인 김○○에게 유증하여 처리케 할 것이냐고 묻자 위 김○○는 고개를 끄덕거렸고, 다시 유언집행자로 조카인 김○○를 지정하겠느냐고 묻자 역시 고개를 끄덕거렸으며, 그 과정에서 그 옆에 있던 3남인 원심공동피고 김○○가 일본말로 “아버지 힘내세요”라고 외치자 위 김○○는 고개를 끄덕거렸던 사실, 변호사 임○○은 위와 같은 취지의 유언을 기재한 증서에 위 김○○의 서명을 받으려고 하였으나 위 김○○는 위 증서에 직접 서명할 기력이 없는 상태였으므로 3남인 위 김○○가 위 김○○의 손에 필기구를 쥐어주고 그 손을 잡고 서명하게 한 사실, 위 김○○는 그 후 병세가 계속 악화되어 같은 날 20:30경

480) 대법원 2002. 09. 24. 선고 2002다35386 판결.

481) 대법원 1996. 04. 23. 선고 95다34514 판결.

같은 병원에서 사망한 사실을 인정한 다음, 민법 제1068조는 공정증서에 의한 유언은 유언자가 증인 2인이 참여한 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하고 공증인이 이를 필기 낭독하여 “유언자와 증인이” 그 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인하여야 한다고 규정하여 공정증서에 의한 유언에 관하여 형식과 절차를 엄격히 규정하고 있는데, 위 인정 사실에 의하면 유언자인 위 김○○는 변호사 임○○이 일정 내용의 유언취지를 묻자 고개를 끄덕거렸을 따름이므로 이를 들어 유언자인 위 김○○가 변호사 임○○의 면전에서 유언의 취지를 구수하여 그 공정증서가 작성된 것으로 볼 수는 없고 따라서 위 김○○의 공정증서에 의한 유언은 무효이다.⁴⁸²⁾

(3) 유언자가 공정증서로 유언 중 사망한 경우

유언자가 유언의 취지를 구수하고 필기를 승인한 다음에 자기의 서명이나 또는 기명날인을 한 후에, 증인이나 공증인이 밝아야 할 절차가 아직 남아있는 단계에서 사망한 경우, 증인과 공증인이 나머지 절차를 속행하여 완결하면 그 유언서는 유효한가? 형식적으로는 공정증서가 완전히 작성되지 않았으므로 유언은 완료되었다고 할 수 없으나, 유언자의 의사로서의 유언은 그의 서명이나 기명날인으로 완결되었다고 할 수 있기 때문에 유효하다고 긍정하는 것이 타당하다.⁴⁸³⁾

(4) 유언공정증서 작성례와 구비서류

(가) 유언공정증서 작성례

공정증서에 의한 유언은 유언자가 공증증인 2인이 참여한 변호사의 면전에서 유언의 취지를 말하며, 변호사가 이를 기록하고 읽어 들려준 뒤에 유언자와 공증증인이 그것이 정확한 것임을 승인한 다음 각기 서명 또는 기명날인한다(민법 제1068조).

(나) 구비서류

유언자의 신분증, 도장, 기본증명서, 가족관계증명서 각 1통, 수증자의 기본증명서 1통, 증인의 가족관계증명서 1통, 신분증, 도장(증인은 유언자와 친인척이 아니어야 한다), 그 밖의 부동산이 있는 경우 건축물대장, 토지대장, 부동산등기부등본 등이 필요하다.

(다) 공증수수료

목적가액(금액)×0.0015+21,500원이다.

482) 대법원 1993. 06. 08. 선고 92다8750 판결.

483) 광윤직, 앞의 책(상속법), 385면.

마. 비밀증서에 의한 유언

(1) 의 의

유언자가 필자의 성명을 기입한 증서를 엄봉·날인하고 이를 2인 이상의 증인의 면전에 제출하여 자기의 유언서임을 표시한 후 그 봉서표면에 제출연월일을 기재하고 유언자와 증인이 각자 서명 또는 기명·날인함으로써 성립한다. 그리고 봉서는 그 표면에 기재된 날로부터 5일 내에 공증인 또는 법원서기에게 제출하여 그 봉서상에 확정일자인을 받아야 한다(민법 제1069조). 즉, 유언자 본인이 자필로 유언의 전문을 쓰거나 인쇄하거나 타이프라이터로 친 것, 또는 다른 사람에게 쓰게 한 후 반드시 유언자 본인의 성명을 직접 쓴 유언증서를 엄봉하여 날인한다. 그리고 이 증서를 2인 이상의 증인의 면전에 제출하여 자기의 유언서임을 표시한다. 봉서표면에 유언서의 제출 연월일을 기재하고 유언자와 증인이 각자 서명 또는 기명·날인을 한다. 그런 후 이 유언봉서는 그 표면에 기재된 날로부터 5일 이내에 공증 사무실 또는 가정법원에 제출하여 그 봉인상에 확정일자인을 받아야 한다. 이러한 비밀유언의 방식은 문자를 읽을 수는 있으나 쓸 줄을 모르는 자도 내용을 비밀로 하는 유언을 할 수 있다는 데 특색이 있다. 다만, 위조·변조의 위험은 적으나 분실·멸실 또는 훼손의 위험은 크다. 그리고 절차가 복잡하고, 비용도 들며 검인이 필요하다는 단점이 있다.

(2) 요 건

(가) 유언의 취지를 적고 또한 그 필자의 성명을 기입한 증서를 작성하여야 한다.

유언의 내용을 누가 적어도 상관없다. 또한 증서에 유언자의 서명이나 기명·날인 할 필요는 없으나 그 필기자가 누구인지는 밝혀야 한다. 그리고 증서에 그 작성연월일을 기재할 필요는 없다. 후에 확정일자를 받으면 그 확정일자가 유언능력의 유무나 유언의 전후를 판정하는 기준이 되기 때문이다.

(나) 증서에 엄봉·날인하여야 한다. 엄봉은 봉투에 넣거나 또는 봉지로 싸서 그 봉투나 봉지를 훼손하지 않고는 개봉할 수 없도록 굳게 봉하는 것을 말한다. 날인은 봉한 곳에 날인한다는 뜻이며, 도장은 목도장도 상관없다. 다만, 봉서에 사용한 도장과 동일하여야 한다.

(다) 엄봉한 날인증서를 2인 이상의 증인의 면전에 제출하여 자기의 유언임을 표시하여야 한다.

(라) 봉서표면에 제출 내지 표시한 연월일을 기재하고, 유언자와 증인이 각자 서명 또는 기명·날인을 하여야 한다. 표시방법은 반드시 언어로 하는 것은 아니다. 언어를 사용하지 못한 자는 글을 써서 표시하여도 상관없다. 증인에 관한 규정은 녹음에 의한 유언방식의

증언을 참조한다.

(마) 유언봉서는 그 표면에 기재된 날, 즉 제출 연월일로부터 5일 이내에 공증인 또는 법원서기에게 제출하여 그 봉인 위에 확정일자인을 받아야 한다.

(3) 유효한 자필증서로서 의제

비밀증서에 의한 유언서를 작성하는 과정에서 엄봉을 하지 않는다든지 하여 비밀증서로서의 방식에 흠결이 있는 경우에는 유언증서의 전문, 연월일, 주소, 성명을 자필하고 날인하여 앞서 설명한 자필증서의 방식에 적합한 때에는 자필증서에 의한 유언으로서 유효하게 된다(민법 제1071조). 예컨대 봉서 표면에 날인한 인장과 유언자가 기명날인한 인장이 서로 다르거나, 소정의 기간 내에 확정일자인을 받지 않은 때에는 비밀증서 유언으로서는 유효하게 성립하지 않지만, 자필증서로서 완전하다면 이는 자필증서로서 유효한 것으로 된다.

바. 구수(口授)증서에 의한 유언

(1) 의 의

질병 기타 급박한 사유로 인하여 전에 설명한 4가지 방식(자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서)에 의할 수 없는 경우에 유언자가 2인 이상의 증인의 참여로 그 1인에게 유언의 취지를 구수하고 그 구수를 받은 자가 이를 필기 낭독하여 유언자와 증인이 그 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인함으로써 성립한다(민법 제1070조 제1항).

(2) 요 건

(가) 앞서 설명한 네 가지 유언방식에 의한 유언을 할 수 없는 급박한 사유가 있어야 한다. 급박한 사유란 사망이 시간적으로 가깝다고 할 수 있는 상태를 말한다. 예컨대 부상으로 사망이 가까운 경우, 선박·항공기 등 조난, 전염병 때문에 교통이 차단된 장소에 있는 경우 등을 들 수 있다.

(나) 2인 이상의 증인이 필요하다. 증인에 관한 것은 녹음에 의한 유언의 증인과 같다. 다만 보통방식에 의한 유언의 경우에는 유언자가 유언능력이 있는 금치산자인 때에는 의사가 그의 정신 상태를 유언서에 부기하고 서명날인 하여야 하나(민법 제1063조 제2항), 구수증서유언의 경우에는 이를 적용하지 않는 것으로 하고 있다(민법 제1070조 제3항). 따라서 구수증서의 유언의 경우에는 증인들이 유언자의 정신상태가 유언할 수 있을 정도의 의사능력을 갖추고 있음을 확인하여야 할 의무가 있다.

(다) 유언자가 증인 중의 1인에게 유언의 취지를 구수하고, 구수를 받은 증인이 이를 필기하여야 한다. 구수란 구두의 진술, 언어에 의한 의사표시를 말한다. 여기서 ‘유언취지의 구수’라 함은 말로써 유언의 내용을 상대방에게 전달하는 것을 뜻하는 것이므로, 증인이 제3자에 의하여 미리 작성된, 유언의 취지가 적혀 있는 서면에 따라 유언자에게 질문을 하고 유언자가 동작이나 간략한 답변으로 긍정하는 방식은, 유언 당시 유언자의 의사능력이나 유언에 이르게 된 경위 등에 비추어 그 서면이 유언자의 진의에 따라 작성되었음이 분명하다고 인정되는 등의 특별한 사정이 없는 한 민법 제1070조 소정의 유언취지의 구수에 해당한다고 볼 수 없다.⁴⁸⁴⁾ 따라서 유언 당시에 자신의 의사를 제대로 말로 표현할 수 없는 유언자가 유언취지의 확인을 구하는 변호사의 질문에 대하여 고개를 끄덕이거나 “음”, “어”라고 말한 것만으로는 민법 제1070조가 정한 유언의 취지를 구수한 것으로 볼 수 없다. 또한 증인의 물음에 단순히 머리를 흔들어 답하는 정도는 구수라고 할 수 없다.

필기의 용구나 자재에는 제한이 없으며 타자기를 사용해도 무방하다. 필기는 반드시 다른 증인의 참여 아래 하여야 한다.

(라) 필기한 유언의 취지를 유언자와 증인에게 낭독하고 그 필기가 정확함을 이들이 승인한 후에 각자 서명 또는 기명날인을 하여야 한다.

서명은 자신이 하여야 하나 기명날인은 반드시 본인이 할 필요는 없다고 본다. 날인은 지장이라도 무방하다고 본다.

(마) 구수증서에 의한 유언은 증인 또는 이해관계인이 급박한 사정이 종료한 날로부터 7일 이내에 법원에 그 검인을 신청하여야 한다(민법 제1070조 제2항). 따라서 유언자의 사망 시의 검인을 따로 받을 필요가 없다. 민법 제1070조의 규정에 따라 유언자의 질병으로 인하여 구수증서의 방식으로 유언을 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 유언이 있는 날에 급박한 사유가 종료하였다고 할 것이므로 유언이 있는 날로부터 7일 이내에 하여야 할 검인신청을 하지 않을 경우, 즉 위 기간을 도과한 검인신청은 부적법하다.⁴⁸⁵⁾

갑이 입원하고 있던 병원에서 그가 대표이사로 재직하던 회사의 부사장과 비서인 을을 참석하게 하여 을로 하여금 계쟁토지를 병의 단독 소유로 한다는 등의 유언을 받아쓰게 하여 유언서를 작성한 후 갑이 사망하자 을은 그 사망 직후 같은 회사 직원으로 하여금 위 유언서를 정서하게 하였고 정서된 유언서는 합동법률사무소에서 갑의 처의 촉탁에 의하여 그 사본이 원본과 상위 없다는 내용의 인증을 받은 경우 갑의 유언은 민법 제1070조 제1항에 정한 구수증서에 의한 유언인데 같은 조 제2항에 따라 유언의 증인 또는 이해관계

484) 대법원 2006. 03. 09. 선고 2005다57899 판결.

485) 대법원 1986. 10. 11. 자 86스18 결정.

인이 급박한 사정이 종료한 날로부터 7일 이내에 법원의 검인을 받았다고 인정할 증거가 없어 갑의 유언은 그 효력이 없다.⁴⁸⁶⁾

(3) 다른 방식에 의한 유언이 객관적으로 가능한 경우 구수증서에 의한 유언이 가능한지

자필증서, 녹음, 공정증서 및 비밀증서의 방식에 의한 유언이 객관적으로 가능한 경우, 구수증서에 의한 유언이 가능한가 여부에 대하여 판례⁴⁸⁷⁾는 “민법 제1065조 내지 제1070조가 유언의 방식을 엄격하게 규정한 것은 유언자의 진의를 명확히 하고 그로 인한 법적 분쟁과 혼란을 예방하기 위한 것이므로, 법정된 요건과 방식에 어긋난 유언은 그것이 유언자의 진정한 의사에 합치하더라도 무효라고 하지 않을 수 없는데, 민법 제1070조 제1항이 구수증서에 의한 유언은 질병 기타 급박한 사유로 인하여 민법 제1066조 내지 제1069조 소정의 자필증서, 녹음, 공정증서 및 비밀증서의 방식에 의하여 할 수 없는 경우에 허용되는 것으로 규정하고 있는 이상, 유언자가 질병 기타 급박한 사유에 있는지 여부를 판단함에 있어서는 유언자의 진의를 존중하기 위하여 유언자의 주관적 입장을 고려할 필요가 있을지 모르지만, 자필증서, 녹음, 공정증서 및 비밀증서의 방식에 의한 유언이 객관적으로 가능한 경우까지 구수증서에 의한 유언을 허용하여야 하는 것은 아니다”라고 판시하여 부정하고 있다.

486) 대법원 1992. 07. 14. 선고 91다39719 판결.

487) 대법원 1999. 09. 03. 선고 98다17800 판결.

[서식] 구수증서에 의한 유언서

유언서

유언자 ○○시 ○○구 ○○로 10, 정○석은 20○○. ○. ○. 유언자 본인 자택에서 다음과 같이 유언을 구술하다.

1. 가. 장남 정○준에게는 ○소재 대지 ○제공미터를 상속한다.
나. 차남 정○영에게는 ○소재 대지 ○제공미터를 상속한다.
다. 처 강○에게는 ○소재 대지 ○제공미터와 ○은행 예금 ○원을 상속한다.
2. 위 다. 이외의 동산은 일단 장남 정○준에게 상속시키되 유언자의 처와 협의하여 나누어도 좋다.
3. 장남 정○준은 내가 사망 후 차남 정○영의 대학졸업 시까지 학자금을 부담하며 학업에 지장이 없도록 하여야 한다.
4. 유언집행자로서 유언자의 동생인 정○복을 지정한다.
5. 장남, 차남 등은 협조하여 어머니에게 효도를 다 하며 형제간에 화목하여야 한다.
위 취지의 유언자 구수를 증인 김○수가 필기한 후 유언자 및 다른 증인에게 낭독해 준 바 모두 필기가 정확함을 승인하였다.

20○○년 ○월 ○일

유언자 정○석 (인)

필기자 증인 김○수 (인)

주소 ○○시 ○○대로 10(○○동)

직업 변호사

증인 이○복 (인)

주소 ○○시 ○○대로 12(○○동)

직업 회사원

제2관 유언의 효력

1. 유언의 효력발생 시기

유언은 유언을 하는 당시에 성립하지만 그 효력은 유언자가 사망한 때에 발생한다(민법 제1073조 제1항).

가. 조건부 또는 기한부 유언

정지조건부 유언일 경우에는 조건이 성취된 때에 효력이 발생(동조 제2항)한다. 정지조건부 유언에 있어서 유언자의 사망 이전에 조건이 성취하면 무조건부 유언이 되고(민법 제151조 제2항), 불성취로 확정되면 해당 유언내용은 무효로 된다(동조 제3항). 해제조건부 유언에 관하여는 민법의 규정이 없으나 정지조건부 유언의 경우와 동일하다. 유언 내용이 시기 또는 종기를 붙이는 것이 허용되는 것이면 시기부 또는 종기부 유언도 할 수 있다. 예컨대 상속재산분할금지에 관한 유언은 5년 내의 종기부로 하여야 한다(민법 제1042조).

나. 유언에 의한 재단법인의 설립

유언자가 사망한 때에 바로 재단법인이 성립하지 않으며, 유언집행자 또는 상속인이 주무관청의 허가를 얻어 설립등기를 하여야 성립한다(민법 제32조, 제33조).

다. 유언에 의한 친생부인

부 또는 처가 유언으로 부인의 의사표시를 한 때에는 유언집행자는 친생부인의 소를 제기하여야 한다(민법 제850조).

라. 유언에 의한 인지

유언집행자가 가족관계 등록 등에 관한 법률에 정한 바에 따라 신고한 때가 아니라, 유언자가 사망한 때에 생기고 민법 제860조에 의하여 그 자의 출생 시에 소급한다는 것이 통설이다.⁴⁸⁸⁾

488) 박윤직, 앞의 책(상속법), 246면; 김주수·김상용, 앞의 책, 699면; 박병호, 앞의 책, 438면.

2. 유언의 철회

가. 의의

완전히 유효하게 성립된 유언에 대하여 유언자가 특별한 이유 없이 유언의 효력이 발생하기 전에 유언을 철회하는 것을 말한다.

나. 유언의 철회방식

(1) 임의철회

유언자가 유언 또는 생전행위로서 유언의 전부나 일부를 철회할 수 있다(민법 제1108조 제1항). 예컨대 유언자가 살아 있을 때 마음이 변하여 유언을 없애거나 녹음을 지우는 행위, 또는 다시 작성하는 행위 등을 말한다. 철회는 반드시 유언으로 할 필요가 없으며 생전행위로도 가능하다. 유언자는 그 유언을 철회할 권리를 포기하지 못한다(민법 제1108조 제2항).

(2) 법정철회

(가) 의의

임의철회가 없다 하더라도 법률상 유언의 철회가 있는 것으로 하는 것을 법정철회라 한다.

(나) 유언의 저촉

전후의 유언이 저촉되는 경우에는 그 저촉되는 부분의 전 유언은 철회된 것으로 본다(민법 제1109조 전단). 유언 후의 생전행위가 유언과 저촉되는 경우에는 저촉된 부분의 전 유언은 철회된 것으로 본다(민법 제1109조 후단). 예컨대 유언자가 장남에게 현재 살고 있는 단독주택 1채를 준다고 하는 자필증서의 유언을 작성해 놓았지만 그동안 들었던 병원비 때문에 그 집을 처분하였고 그 후 유언자가 사망한 경우에 유언자가 생전행위로서 유증의 목적인 집을 처분해버렸기 때문에 장남에게 집을 주겠다고 한 유언은 철회한 것으로 한다는 것이다.

유언 후의 생전행위가 유언과 저촉되는 경우에는 민법 제1109조에 의하여 그 저촉된 부분의 전(前) 유언은 이를 철회한 것으로 보지만, 이러한 생전행위를 철회권을 가진 유언자 자신이 할 때 비로소 철회 의제 여부가 문제될 뿐이고 타인이 유언자의 명의를 이용하여 임의로 유언의 목적인 특정 재산에 관하여 처분행위를 하더라도 유언 철회로서의 효력은

발생하지 아니하며, 또한 여기서 말하는 ‘저촉’이라 함은 전의 유언을 실효시키지 않고서는 유언 후의 생전행위가 유효로 될 수 없음을 가리키되 법률상 또는 물리적인 집행불능만을 뜻하는 것이 아니라 후의 행위가 전의 유언과 양립될 수 없는 취지로 행하여졌음이 명백하면 족하다고 할 것이고, 이러한 저촉 여부 및 그 범위를 결정함에 있어서는 전후 사정을 합리적으로 살펴 유언자의 의사가 유언의 일부라도 철회하려는 의사인지 아니면 그 전부를 불가분적으로 철회하려는 의사인지 여부를 실질적으로 집행이 불가능하게 된 유언 부분과 관련시켜 신중하게 판단하여야 한다.⁴⁸⁹⁾

망인이 유언증서를 작성한 후 재혼하였다거나, 유언증서에서 유증하기로 한 일부 재산을 처분한 사실이 있다고 하여 다른 재산에 관한 유언을 철회한 것으로 볼 수 없다.⁴⁹⁰⁾

(다) 파훼로 인한 유언의 철회

유언자가 고의로 유언증서나 유증의 목적물을 파훼한 때에는 그 파훼한 부분에 관한 유언은 철회된 것으로 본다(민법 제1110조). 파훼란 물건의 형체 또는 효용을 잃게 하는 모든 행위를 말한다. 예컨대 서명란을 두 줄로 그어버린다는가, 유언증서를 찢어버린다는가 하는 행위를 말한다. 유언자가 유언을 철회한 것으로 볼 수 없는 이상, 유언증서가 그 성립 후에 멸실되거나 분실되었다는 사유만으로 유언이 실효되는 것은 아니고 이해관계인은 유언증서의 내용을 입증하여 유언의 유효를 주장할 수 있다.⁴⁹¹⁾ 그러나 실제문제로서 그러한 입증은 매우 곤란할 것이다.

다. 유언철회의 효과

(1) 유언의 소급적 소멸

유언이 철회된 경우에는 유언자가 사망하여도 유언은 아무런 효력이 발생하지 않는다. 즉, 유언은 처음부터 없었던 것과 마찬가지로 된다.

(2) 철회의 철회

유언의 철회가 있는 후에 그 철회를 다시 철회하는 경우, 먼저 철회되어서 실효한 유언의 효력이 되살아나는지 문제이다. 우리 민법은 이에 관한 명문 규정이 없으나, 학설은 대체적으로 부활하는 것으로 보고 있다.⁴⁹²⁾

489) 대법원 1998. 06. 12. 선고 97다38510 판결.

490) 대법원 1998. 05. 29. 선고 97다38503 판결.

491) 대법원 1996. 09. 20. 선고 96다21119 판결.

492) 박윤직, 앞의 책(상속법), 244면; 김주수·김상용, 앞의 책, 698면; 박병호, 앞의 책, 443

(3) 철회의 취소

철회의 유언이나 저촉유언이 착오나 사기·강박으로 취소할 수 있게 되는 수가 있다. 그 밖에 유언의 철회로 의제되는 생전처분을 한 경우에 그 처분행위가 무능력·착오·사기나 강박을 이유로 취소될 수 있다. 이들 각 경우에 제1유언이 부활하는가? 이에 관하여 명문의 규정이 없어 민법총칙의 취소의 일반원칙으로 처리된다고 본다.⁴⁹³⁾

3. 유언의 무효(민사사건)

가. 의 의

유언자의 사망 후 유언의 내용상 또는 형식상 요건의 흠결로 인하여 처음부터 유언으로서 성립될 수 없는 경우를 말한다. 유언의 무효는 민사사건이다(가사소송관계법령의 주요 내용과 그 시행에 따른 유의사항, 1991. 1. 3. 송무심의 1호지침). 따라서 확인의 재판에 관한 일반원칙이 적용된다.

나. 원 인

방식이 흠결된 유언, 유언무능력자의 유언, 수증결격자에 대한 유언, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반된 사항을 내용으로 하는 유언, 강행법규에 위반되는 유언, 법정사항 이외의 사항을 내용으로 하는 유언, 유언자의 생전행위에 의하여 실현되었거나 유언자의 사망 전에 실현된 것을 내용으로 하는 유언 등이다.

방식이 흠결된 유언의 사례로 유언자인 망 청구 외 1은 1900. 8. 15 뇌혈전증으로 김○○ 내과에 입원하여 같은 달 19까지 치료를 받았으나 치료기간 중 언어장애, 좌반신마비 등으로 의식불명 상태가 계속되어 소생의 가망이 없자 전남대학교 의과대학 부속병원으로 옮겨졌으나 여전히 좌측 상하지는 마비되어 있고, 혼수상태가 지속되어 환자와의 대화는 하지 못하고 묻는 말에 알아듣는 표정만 짓고 있었으며 치료 중 같은 해 9. 8에는 정신상태가 다소 호전되고 이견 유언을 한 날인 같은 달 9에는 정신 상태는 상당히 호전되고 의식상태도 한층 좋아졌으며 언어는 약간 가능한 정도였는데 당시 상태는 의사가 환자에게 내가 의사냐고 다그쳐 물으면 말은 못하고 고개만 끄덕끄덕 하고 반응이 있을 정도로서,

면.

493) 박윤직, 앞의 책(상속법), 244면; 법원행정처, 『상속등기실무』, 246면; 유언을 신분상의 것과 재산상으로 나누고 전자는 인지취소(민법 제861조)의 규정이 유추적용 된다는 견해가 있다[박병호, 앞의 책, 443면].

의학상 가면성 정신 상태에 놓여 있었던 사실, 망 청구 외 1은 입원 중 의사나 간호원, 다른 가족들과 대화를 나눈 일이 없는 사실, 이견 유언서를 작성할 당시에도 망 청구 외 1은 위와 같은 상태로 산소마스크를 착용하고 침대에 누워 있었는데 공증인 이○재가 망 청구 외 1에게 청구 외 박○○와 박○남을 증인으로 한다고 말하자 망 청구 외 1은 말은 하지 않고 고개만 끄덕끄덕 한 사실, 이견 유언서는 옆에 있던 친족 중의 한 사람이 공증인에게 말하여 주면 공증인이 유언자에게 그 취지를 말하여 주고 “그렇소”하고 물으면, 유언자는 말은 하지 않고 고개만 “끄덕 끄덕”하여 이 내용을 위 공증인의 사무원인 소외 송○○이 필기하고 공증인이 낭독하는 방식으로 작성된 사실을 각 적법히 인정하고 나서 공정증서에 의한 유언은 유언자가 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하여야 함을 요하는데, 위 인정사실에 의하면 이견 유언은 유언자가 공증인에게 “구수”하여 작성된 것으로 볼 수 없어 무효이다.⁴⁹⁴⁾

4. 유언의 취소

가. 의 의

유언자의 사망 후 사기·강박 등의 원인으로 하여 상속인, 유언집행자 그 밖의 이해관계인이 유언의 효력발생을 방지하는 행위를 말한다.

나. 원 인

유언자가 법률행위의 내용의 중요부분에 착오를 일으켜 유언을 한 경우에 유언자, 상속인 또는 유언집행자는 그 유언을 취소할 수 있다(민법 제109조 제1항 본문 및 제140조). 예컨대 자신의 병간호를 한 사람에게 유증할 것을 결심했는데, 자신의 병간호를 한 사람이 A가 아니라 B라고 착오하고 B에게 유증한 경우에는 중요부분의 착오로서 유언을 취소할 수 있다. ‘법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때’란 표의자가 그러한 착오가 없었더라면 그 의사표시를 하지 않으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 하고 보통 일반인도 표의자의 처지에 섰더라면 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 한다.⁴⁹⁵⁾

유언자가 사기 또는 강박에 의해 유언을 한 경우에 유언자, 상속인 또는 유언집행자는 그 유언을 취소할 수 있다(민법 제110조 제1항 및 제140조). ‘사기에 의한 유언’이란 타인

494) 대법원 1980. 12. 23. 선고 80므18 판결.

495) 대법원 1996. 3. 26. 선고 93다55487 판결.

의 기망(欺罔)행위로 인해 착오에 빠지고 그 상태에서 행한 유언을 말하고, ‘강박에 의한 유언’이란 타인의 강박(強迫)행위로 인해 공포심을 가지게 되고 그 해악을 피하기 위해 마음에 없이 행한 유언을 말한다. 또한 유언이 부담부 유증으로 이루어진 경우 이 유증을 받은 사람이 그 부담의무를 이행하지 않은 때에는 상속인 또는 유언집행자는 상당한 기간을 정하여 이행할 것을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 않은 때에는 법원에 유언의 취소를 청구할 수 있다. 그러나 제3자의 이익을 해하지 못한다(민법 제1111조).

다. 심판절차

부담부 유증의 취소를 청구하는 경우에는 라류가사비송사건으로 가정법원에 심판을 제기해야 한다(가사소송법 제2조 제1항 제2호 가목 48) 및 제39조 제1항). 부담부 유증의 취소를 청구하는 심판은 가사소송법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 피고의 주소지 관할의 가정법원에 청구한다(가사소송법 제13조 제1항).

상세한 내용은 ‘부담 있는 유언의 취소’ 434면 참조한다.

5. 유 증

가. 유증이란

개인의 소유재산에 대하여 자유로이 처분하거나 남에게 줄 수 있는 자유가 인정되는 이상 그가 죽어서도 자기 재산을 자유로이 처분할 수 있는 방법이 유증이다. 즉, 유증이란 유언자가 유언에 의하여 그 재산상의 이익(채무의 면제도 포함)을 수증자에게 무상으로 증여하는 단독행위를 말한다. 사인증여는 사인행위인 점에서 유증과 같으나 그것은 계약이기 때문에 단독행위인 유증과 구별된다. 그러나 재산의 사후처분인 사인증여는 실질적으로는 유증과 비슷하다. 따라서 민법은 사인증여에는 유증에 관한 규정을 준용하고 있다(민법 제562조). 다만, 유언능력, 유증의 승인과 포기, 유언의 방식에 관한 규정은 사인증여에 규정되지 않는다.

증여자와 수증자의 관계가 피상속인과 상속인의 관계에 있다 하여 이를 특별한 사정이 없는 한 유증 내지는 사인증여의 의미로 보아야 한다고 할 수는 없다.⁴⁹⁶⁾

496) 대법원1991. 08. 13. 선고 90다6729 판결.

나. 유증의 종류

유증에는 민법상 ‘포괄적 유증’과 ‘특정적 유증’이 있고, 조건이나 기한 또는 부담을 붙일 수 있으므로 조건부 유증(민법 제1073조 제2항, 제1089조 제2항)과 부담부 유증(민법 제1088조, 제1111조)이 있다. 기한부 유증도 유효한 것으로 해석하는데 이설이 없다.

다. 수증자와 유증의무자

(1) 수증자

(가) 의 의

유증으로 인하여 재산상 이익을 받는 자를 수증자라하며 수증자는 유언에서 수증자로 지정되고 유언자의 사망 후까지 생존하고 있는 사람을 말한다. 유언자가 사망하기 전에 수유자가 먼저 사망한 경우에는 유증의 효력이 생기지 않으므로 수증자가 아니다(민법 제1089조 제1항). 정지조건부 유증에 있어서는 수증자는 조건성취 시에 생존하고 있어야 하며, 조건의 성취 전에 사망한 때에는 그 효력이 생기지 않는다(민법 제1089조 제2항).

(나) 수증자의 자격

수증자는 권리능력자이면 되므로 자연인은 물론 법인도 유증이 효력이 발생하였을 때 존재하면 수증자로 될 수 있다는데 이설이 없다. 태아는 후에 살아서 출생한 경우에만 수증자가 되고(민법 제1064조, 제1000조 제3항), 그 밖에 권리능력이 없는 사단재단·법인, 설립 중의 법인도 수증자가 된다고 본다. 상속결격 있는 자는 수증자로 되지 못한다(민법 제1064조, 제1004조).

(2) 유증의무자

유증을 실행할 의무를 지는 자가 유증의무자이다. 유언집행자, 상속인, 상속재산관리인 등 법률이 지정하는 자가 유증의무자로 된다.

(3) 유증의 포기과 사해행위

유증을 받을 자는 유언자의 사망 후에 언제든지 유증을 승인 또는 포기할 수 있고, 그 효력은 유언자가 사망한 때에 소급하여 발생하므로(민법 제1074조), 채무초과 상태에 있는 채무자라도 자유롭게 유증을 받을 것을 포기할 수 있다. 또한 채무자의 유증 포기가 직접적으로 채무자의 일반재산을 감소시켜 채무자의 재산을 유증 이전의 상태보다 악화시킨다고 볼 수도 없다. 따라서 유증을 받을 자가 이를 포기하는 것은 사해행위 취소의 대상이

되지 않는다.⁴⁹⁷⁾

라. 포괄적 유증

(1) 의 의

적극·소극의 재산을 포함하는 상속재산의 전부 또는 그 분수적 부분 내지 비율에 의한 유증을 말한다. 예컨대 상속재산의 3분의 1 또는 2할을 주는 것을 말한다. 그러나 특정된 부동산을 주거나 금 1,000만 원을 주는 것은 포괄적 유증이 아니다.

유증이 포괄적 유증인가 특정 유증인가는 유언에 사용한 문언 및 그 외 제반 사정을 종합적으로 고려하여 탐구된 유언자의 의사에 따라 결정되어야 하고, 통상은 상속재산에 대한 비율의 의미로 유증이 된 경우는 포괄적 유증, 그렇지 않은 경우는 특정 유증이라고 할 수 있지만, 유언공정증서 등에 유증한 재산이 개별적으로 표시되었다는 사실만으로는 특정 유증이라고 단정할 수는 없고 상속재산이 모두 얼마나 되는지를 심리하여 다른 재산이 없다고 인정되는 경우에는 이를 포괄적 유증이라고 볼 수도 있다.⁴⁹⁸⁾ 이는 유언공정증서의 유증대상 부동산 목록에 소외 망 박○○ 소유의 부동산 중 일부가 누락되어 있고, 이 사건 유언공정증서에 망 박○○의 채무에 관한 아무런 기재가 없는 점을 들어 위 박○○가 이 사건 각 부동산을 원고에게 특정 유증하였다는 사례이다.

(2) 포괄적 유증의 효과

(가) 유증이 단순유증인 경우에는 유언자가 사망한 때로부터 그 효력이 발생하며, 유언에 정지조건이 있는 경우에 그 효력은 조건이 성취한 때로부터 생긴다.

(나) 포괄적 유증을 받은 자는 상속인과 동일한 권리의무가 있다(민법 제1078조).

무릇 포괄적 유증이란 적극재산은 물론, 소극재산 즉 채무까지도 포괄하는 상속재산의 전부 또는 일부의 유증을 말하는 것이고, 포괄적 수증자는 재산상속인과 동일한 권리 의무가 있는 것으로서(민법 제1078조), 따라서 어느 망인의 재산 전부(적극재산 및 소극재산)가 다른 사람에게 포괄적으로 유증이 된 경우에는 그 망인의 직계비속이라 하더라도 유류분 제도가 없는 한, 그가 상속한 상속재산(적극재산 및 소극재산)이 없는 것이므로 그 망인의 생전 채무를 변제할 의무가 없다.⁴⁹⁹⁾

(다) 포괄적 수증자도 유증을 승인하거나 또는 포기할 수 있다. 유증의 승인·포기규정

497) 대법원 2019. 1. 17. 선고 2018다260855 판결.

498) 대법원 2003. 5. 27. 선고 2000다73445 판결.

499) 대법원 1980. 02. 26. 선고 79다2078 판결.

(민법 제1074조)이 별도로 규정되어 있으나 포괄적 수증자는 이 규정을 적용하지 않고 앞서 설명하였던 상속의 승인·포기(민법 제1019~제1044조)에 관한 규정이 적용된다. 이는 포괄적 수증자도 상속인과 동일한 권리의무관계가 있기 때문이다.

(라) 포괄적 유증의 무효·실효 : 포괄적 유증의 효력이 발생하지 않거나 수증자가 이를 포기한 때에는 그 재산은 상속인에게 귀속한다(민법 제1090조 본문). 가령 수증자가 유증을 포기한 때, 유언능력이 없는 자가 유증을 한 때, 수증자가 유언의 효력발생 시에 결격자인 때 등 그 유증의 재산은 유언자의 상속인에게 돌아간다. 그러나 유언자가 유언으로 다른 의사표시를 한 때에는 그 의사에 의한다(민법 제1090조 단서).

마. 특정적 유증

(1) 의 의

개개의 재산상의 이익을 구체적으로 특정하여 유증의 내용으로 하는 것이다. 예컨대 부동산 몇 번지의 택지를 준다든가, 현금 1,000만 원을 준다든가, ○○주식회사 주식 1,000주를 준다든가 하는 등을 말한다.

유증한 재산이 개별적으로 표시되었다는 사실만으로는 특정 유증이라고 단정할 수 없고 피상속인의 상속재산이 얼마가 되느냐를 심리하여 다른 재산이 없다고 인정되지 않는 한 이를 포괄적 유증으로 볼 수도 있기 때문이다.⁵⁰⁰⁾

(2) 특정적 유증의 효과

(가) 유언의 효력발생시기

유증이 단순유증인 경우에는 유언자가 사망한 때로부터 곧 효력이 발생하며, 유언에 정지조건이 있는 경우에 그 효력은 조건이 성취한 때로부터 생긴다(민법 제1073조).

(나) 유증목적물의 귀속시기

특정 유증에 있어서 목적인 재산권은 유언이 효력을 발생함과 동시에 수증자에게 이전(물권적 효력)하는가? 또는 유증 의무자에게 유증 실행의무가 생기고 그 이행을 기다려서 비로소 이전(채권적 효력)되는가? 민법은 물건변동에 관하여 성립요건주의를 취하고 있으므로 유증의 효력은 위의 후자의 견지에서 채권적이라고 한다. 따라서 목적 재산권은 일단 상속인에게 귀속하고, 수증자는 유증의무자에 대하여 유증을 이행할 것을 청구할 수 있는

500) 대법원 1978. 12. 13. 선고 78다1816 판결.

채권을 취득한다.

특정 유증은 상속과 같은 효력을 가지는 포괄유증과는 달리 유증자의 재산을 상속한 상속인들에 대해 채권적인 유증이행청구권만 가지므로, 유증에 따른 소유권이전등기를 하지 아니한 채 제3자에게 수증재산에 대한 소유권주장 등을 할 수 없다.⁵⁰¹⁾

(다) 수증자의 과실취득권

수증자는 유증의 이행을 청구할 수 있는 때로부터 그 목적물의 과실을 취득한다. 그러나 유언자가 유언으로 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다(민법 제1079조). 그리고 유증의무자가 유언자의 사망 후에 그 목적물의 과실을 수취하기 위하여 필요비를 지출한 때에는 그 과실의 가액의 한도에서 과실을 취득한 수증자에게 상환을 청구할 수 있다(민법 제1080조).

(라) 유증의무자의 비용상환청구권

유증의무자가 유증자의 사망 후에 그 목적물에 대하여 비용을 지출한 때에는 유치권의 비용상환청구권에 관한 규정이 준용된다(민법 제1081조).

(마) 유증의무자의 담보책임(민법 제1082조)

불특정물을 유증의 목적으로 한 경우에는 유증의무자는 그 목적물에 대하여 매도인과 같은 담보책임이 있다. 그리고 목적물에 하자가 있는 때에는 유증의무자는 하자 없는 물건으로 인도하여야 한다.

(바) 유증의 물상대위성

예컨대 갑남은 장남 A에게 현재 살고 있는 단독주택 1채를 준다는 유언을 하고 사망 전에 그 주택이 타인이 고의로 방화를 하여 소실된 경우에 유증자(장남 A)는 불을 낸 사람에게 불법행위로 인한 손해배상 등을 청구할 수 있는바, 이처럼 목적물을 인도할 수 없는 대신에 그 유증목적물의 멸실, 훼손 또는 점유의 침해에 의한 대상이 있다면 그것으로 권리의 만족을 취할 수 있는 것이 물상대위라 한다.

채권을 유증의 목적으로 한 경우에 유언자가 그 변제를 받은 물건이 상속재산 중에 있는 때에는 그 물건을 유증의 목적으로 한 것으로 본다. 그리고 그 채권이 금전을 목적으로 한 경우에는 그 변제 받은 채권액에 상당한 금전이 상속재산 중에 없는 때에도 그 금액을 유증의 목적으로 한 것으로 본다.

501) 대전지방법원 홍성지원 1988. 01. 15. 선고 87가합160 민사부판결.

(사) 제3자의 권리의 목적인 물건 또는 권리의 유증

유증의 목적인 물건이나 권리가 유언자의 사망 당시에 제삼자의 권리의 목적인 경우에는 수증자는 유증의무자에 대하여 그 제삼자의 권리를 소멸시킬 것을 청구하지 못한다(민법 제1085조. 다른 의사표시가 있는 경우 그 의사표시에 의한다(민법 제1086조)).

(아) 상속재산에 속하지 아니한 권리의 유증(민법 제1087조)

가령 고인이 자기의 재산이 아닌 것을 유증한 경우를 말한다. 유언의 목적이 된 권리가 유언자의 사망 당시에 상속재산에 속하지 아니한 때에는 그 유언은 효력이 없다. 즉, 그 유증은 무효가 된다. 그러나 유언자가 자기의 사망 당시에 그 목적물이 상속재산에 속하지 아니한 것을 알고도 유증의 목적물로 한 때에는 그 유증은 유효하며 따라서 유증이 유효하게 되면 상속인은 그 권리를 취득하여 수증자에게 이전할 의무가 있다. 만약 그 권리를 취득할 수 없거나 그 취득에 과다한 비용을 요할 때에는 그 가액으로 변상할 수 있다.

(자) 특정적 유증의 무효 · 실효

포괄적 유증의 무효 · 실효(430면)를 참조한다.

(3) 특정적 유증의 승인 · 포기

(가) 민법의 규정

포괄적 유증의 승인과 포기는 상속의 승인 포기에 관한 규정(민법 제1019조~제1044조)이 적용되고 특정적 유증의 승인 · 포기는 유증의 승인 · 포기에 관한 규정(민법 제1074조~제1077조)이 적용된다. 따라서 특정적 유증을 받은 사람은 유언자의 사망 후에 언제든지 유증을 승인 또는 포기할 수 있다(민법 제1074조 제1항). 그 효력은 유언자가 사망한 때에 소급하여 그 효력이 생긴다(민법 제1074조 제2항).

(나) 특정적 유증자의 유증의 승인 · 포기의 자유

또한 승인 · 포기의 기한이 정해져 있지 않기 때문에 유증의무자나 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 승인 또는 포기를 확답할 것을 수증자 또는 상속인에게 최고할 수 있다(민법 제1077조 제1항). 만약 그 기간 안에 수증자 또는 상속인이 유증의무자에게 최고에 대한 확답을 하지 않을 때에는 유증을 승인하는 것으로 본다(민법 제1077조 제2항).

(다) 유증의무자의 최고권

특정적 유증을 받은 자가 승인이나 포기를 한 때에는 원칙적으로 취소하지 못한다(민법 제1075조 1항). 그러나 사기·강박·무능력 등 그 의사표시에 하자가 있는 경우에는 취소할 수 있다(민법 제1075조 제2항).

(라) 수증자의 상속인의 승인과 포기

수증자가 승인이나 포기를 하지 않고 사망한 때에는 그 상속인은 상속분의 한도에서 승인 또는 포기를 할 수 있다. 그러나 유언자가 유언으로 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다(민법 제1076조).

(4) 특정 유증을 받은 자는 유증받은 부동산에 대하여 직접 진정한 등기명의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권을 행사할 수 있는지 여부

포괄적 유증을 받은 자는 민법 제187조에 의하여 법률상 당연히 유증 받은 부동산의 소유권을 취득하게 되나, 특정 유증을 받은 자는 유증의무자에게 유증을 이행할 것을 청구할 수 있는 채권을 취득할 뿐이므로, 특정 유증을 받은 자는 유증받은 부동산의 소유권자가 아니어서 직접 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 구할 수 없다. 즉, 특정 유증을 받은 자는 유증 받은 부동산의 소유권자가 아니라 유증의무자에 대한 채권자에 불과하여 제3자에 대하여 직접 진정한 등기명의의 회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구할 수 없다.⁵⁰²⁾

바. 부담부유증

(1) 의 의

수유자에게 유증만 하는 것이 아니라 일정한 채무를 부담시키는 유증이 부담부 유증이다. 조건부 유증은 조건이 이루어지지 아니하면 유증의 효력이 아예 발생하지 않지만, 부담부 유증의 경우 부담 그 자체가 유증 효력·발생·소멸을 좌우하지 못하고 유언자의 사망으로 인하여 유증의 효력이 발생한다.

72세의 남자(망인)가 52세의 여자인 피고와 재혼한 지 8개월 지나 부부간의 증표로서 부동산의 소유명의를 이전해 달라는 요구에 따라 시가 2억 원 정도의 주택을 증여를 원인으로 하여 피고에게 이전해 준 것은 망인과 피고의 결혼 당시의 나이, 결혼 전후의 망인의

502) 대법원 2003. 05. 27. 선고 2000다73445 판결.

부양관계, 결혼 경위 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 이는 부동산을 명의신탁 한 것이라기보다는 망인의 얼마 남지 않은 여생 동안 피고가 배우자로서 또한 보호자로서 망인이 외롭지 아니하게 애정을 가지고 혼인생활을 유지하고 망인을 부양해 줄 것을 조건으로 증여한 것이다.⁵⁰³⁾

(2) 부담의 내용

수유자가 받은 경제적 이익을 일부 수익자에게 주라는 경우가 많지만, 반드시 금전적 가치가 없는 것이라도 무방하고 목적물과 전혀 관계없는 사항을 부담의 내용으로 할 수 있다. 그러나 법률상 구속력이 없는 것은 법적구속력이 없다. 또는 사회질서에 반하는 부담이나 사실상불능인 것을 내용으로 하는 부담은 무효이다.

(3) 부담부유증의 효력

(가) 부담이행의 의무와 청구

부담이행의무자는 수유자이고, 수유자의 상속인도 의무를 부담한다. 부담의 이행청구권자는 상속인과 유언집행자 및 부담이행청구권자로 지정된 사람이다. 수익자도 이행청구권을 가지는가 긍정설⁵⁰⁴⁾과 부정설⁵⁰⁵⁾이 대립하나 긍정설이 타당하다.

(나) 수증자의 책임

부담 있는 유증을 받은 자는 유증의 목적의 가액을 초과하지 아니한 한도에서 부담한 의무를 이행할 책임이 있다(민법 제1088조 제1항). 유증의 목적의 가액이 한정승인 또는 재산분리로 인하여 감소된 때에는 수증자는 그 감소된 한도에서 부담할 의무를 면한다(제2항).

(다) 부담 있는 유언의 취소

① 의 의 : 부담 있는 유증을 받은 자가 그 부담의무를 이행하지 아니한 때에는 상속인 또는 유언집행자는 상당한 기간을 정하여 이행할 것을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 가정법원에 유언의 취소를 청구할 수 있다. 그러나 제3자의 이익을 해하지 못한다(민법 제1111조).

503) 서울고등법원 2004. 09. 16. 선고 2004나9796 판결.

504) 박윤직, 앞의 책(상속법), 262면; 김주수·김상용, 앞의 책, 721면; 이경희, 앞의 책, 546면; 송덕수, 앞의 책, 1967면.

505) 김용한, 앞의 책, 415면; 박병호, 앞의 책, 585면.

② 요건 : 수유자가 그 부담을 이행하지 아니할 것, 상속인 기타 유언집행자가 상당한 기간을 정하여 부담의 이행을 최고 할 것 등의 요건이 있어야 한다.

③ 취소의 심판청구 절차 : 청구권자는 상속인 또는 유언집행자이다. 유언이 부담 있는 유언에 해당하고 수증자가 상속인 또는 유언집행자의 최고를 받고도 그 부담을 이행하지 않을 것을 요건으로 함으로 심리는 이에 대한 여부에 집중된다. 부담 있는 유언을 취소할 것인가의 여부는 유증과 부담의 내용, 불이행의 정도, 그에 대한 수유자의 태도 등의 제반사정을 종합적으로 참작하여 가정법원의 재량으로 정한다. 라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다. 수유자를 절차에 참가하게 하여야 한다(가사소송규칙 제84조 제2항). 심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조). 소의 심판이 확정되면 그 유언은 상속개시 시에 소급하여 효력을 잃는다. 따라서 유증의 목적인 재산은 상속인에게 귀속한다. 따라서 부담부 유증으로 이득을 얻고 있는 수증자와 수익자는 상속인에 대하여 부당이득반환의무를 부담하게 된다. 그러나 취소는 제3자의 권리를 해하지 못한다(민법 제1111조 단서). 따라서 취소 전에 유증의 목적물에 관하여 권리를 취득한 제3자는 보호된다.

제3관 구수증서에 의한 유언의 검인

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.40), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

검인이란 유언의 실상을 명확히 하여 유언서의 위조·변조 등을 방지하며 보존을 확실하게 하기 위한 검증절차이다. 따라서 검인은 유언의 유효·무효를 확정하는 절차도 아니고 유언서가 허위인가 진위인가 또한 적법한 것인가의 여부를 판단하는 절차가 아니다.

유언서의 검인은 유언의 집행 전에 유언서의 형식 기타의 상태를 확증하고 그 위조 또는 변조되는 것을 예방하며 그 보존을 확실하게 하기 위한 목적에서 나온 검증절차에 지나지 아니하다 할 것이며, 검인의 실질은 유언서의 형식, 태양 등 오로지 유언의 방식에 관한 일체의 사실을 조사하여 유언서 자체의 상태를 확정하여 그 현상을 명확히 함에 있고, 유언의 효력을 판단함에 있는 것은 아니므로 법원은 유언서의 검인청구가 있을 때에는 유언서의 내용이나 형식이 어떠한지 간에, 이에 대하여 가사심판규칙 제101조에 의하여 조서를 작성함을 요한다고 할 것이며, 그 유언서가 방식을 따르지 아니한 것이라도 그 청구를 각하할 것이 아니다.⁵⁰⁶⁾

질병 기타 급박한 사유로 인하여 전에 설명한 4가지 방식에 의할 수 없는 경우에 유언자가 2인 이상의 증인의 참여로 그 1인에게 유언의 취지를 구수하고 그 구수를 받은 자가 이를 필기 낭독하여 유언자와 증인이 그 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인함으로써 성립한다(민법 제1070조 제1항). 이 유언은 그 증인 또는 이해관계인이 급박한 사유가 종료한 날로부터 7일 내에 법원에 그 검인을 신청하여야 한다(동법 제2항). 검인을 받지 아니하면 구수증서에 의한 유언은 효력이 없다.

2. 심판청구절차

가. 청구권자

청구권자는 증인 또는 이해관계인이다. 증인은 구수증서의 작성에 참여한 증인을 말하며, 이해관계인은 추정상속인, 수유자, 유언집행자 등의 법률상 이해관계인을 말한다. 상속채권자는 이해관계인에 해당하지 않는다.

506) 대법원 1980. 11. 19. 자 80스23 결정.

나. 청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

유언자 ○○○는 20○○. 3. 5. 별지와 같은 내용의 유언을 하였음을 검인한다.
 * 또는 「~하였음을 확인한다.」
 라는 심판을 구합니다.

다. 첨부서류

유언자의 가족관계증명서, 제적등본 및 말소된 주민등록표등본, 기본증명서 각 1통, 상속인·수증자의 가족관계증명서, 기본증명서, 주민등록표등본 각 1통, 사망진단서, 유언서 원본(개봉 안 된 것) 등이 필요하다.

라. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 검인 대상이 되는 구수증서마다 1개의 청구로 본다. 따라서 검인대상이 되는 구수증서가 둘이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다.

송달료는 청구인의 수(상속인 포함)×5,200원×6회분이다. 송달료는 법원 구내은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

마. 청구서 제출(관할법원)

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 유언자가 생존 중에는 그 주소지의 가정법원에, 유언자가 사망한 때에는 피상속인의 마지막 주소지에 제출한다. 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원소재지의 가정법원에 제출한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

청구기간은 구수증서에 의한 유언을 하게 된 급박한 사유가 종료한 날로부터 7일 이내에

청구하여야 한다. 즉, 특별한 사정이 없는 한 그 유언이 있는 날에 급박한 사유가 종료하였다고 하겠으므로, 유언이 있는 날로부터 7일 이내에 그 검인신청을 하여야 하고⁵⁰⁷⁾, 그 기간이 경과된 후에 제기된 검인신청은 부적법하다.⁵⁰⁸⁾ 신청기간을 도과하여 한 검인심판의 효력을 다투는 방법은 신청기간을 도과하여 검인신청을 하였더라도 그 검인의 효력을 다투기 위하여서는 즉시항고를 하는 방법밖에 불복의 길이 없다.⁵⁰⁹⁾ 그 밖에 판례⁵¹⁰⁾를 참조한다.

바. 검인기일의 지정 등

필요한 서류가 갖추어지면 검인기일을 지정한다. 검인기일에는 청구인과 상속인, 구수증서에 기재된 증인, 그 밖의 이해관계인에게 기일을 통지하여 참여의 기회를 주는 것이 바람직하다.

[서식] 구수증서에 의한 유언의 검인청구서

구수증서에 의한 유언의 검인청구	
청 구 인(상속인)	이 ○ 호 (☎) 주민등록번호 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호) 등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)
사건본인(유언자)	이 ○ 호 주민등록번호 마지막 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) 등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)
청 구 취 지	

507) 대법원 1994. 11. 03. 자 94스16 결정.

508) 대법원 1986. 10. 11. 자 86스18 결정; 대법원 1989. 12. 13. 자 89스11 결정.

509) 대법원 1977. 11. 08. 선고 76므15 판결.

510) 대법원 1992. 07. 14. 선고 91다39719 판결.

유언자 망 이○화가 20○○. 5. 25.자 구술한 구수증서에 의한 별지 유언서를 검인한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 피상속인 망 이○화는 슬하에 2남 1녀를 두고 처가 먼저 사망하여 혼자 자녀들을 양육하여 열심히 살아왔으나 회사 출장 시 예견치 못한 교통사고로 치료를 받던 중 합병증이 발생하여 거동이 부자연스럽고 병이 점차 악화되어 어느 정도 병이 호전되면 사무실에서 유언공증을 할 마음을 가지고 있었습니다.
2. 그러던 중 병세가 악화되고 도저히 움직일 수 없어 유언자는 20○○. 1. 23. 처와 가족들이 모인 앞에서 변호사 2명을 증인으로 하여 그들의 입회하에 유언취지를 말하고 대필자를 변호사 임○원으로 하여 유언을 구수하고 대필자 이○원이 이 구수를 받아 그대로 필기하고 유언서를 낭독하여 정확함을 승인한 후 각기 기명 또는 서명날인 한 유언서를 작성하였습니다.
3. 그 후 유언자는 20○○. 3. 25. 사망하였으므로 이 건 유언증서의 검인을 구하고자 청구취지와 같은 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 유언자(사건본인)의 기본증명서, 가족관계증명서, 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 가족관계증명서, 주민등록등(초)본(청구인, 상속인) 각 1통
1. 유언증서 사본 1통
1. 상속인 목록 1통
1. 납부서 1통

20○○. 6. .

위 청구인 이 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

사. 심리대상과 범위

심리의 대상은 유언서에 의한 유언이 유언자의 진의에 의한 것인지의 여부이다. 유언자가 생존하고 있을 때에는 그 유언자를, 유언자가 사망한 때에는 유언에 참여한 증인, 의사, 유언자의 친족 등을 신문하는 등의 방법으로 유언자의 유언 당시의 병상이나 정신상태 기타 유언서작성 당시의 일체의 사정을 조사한다. 구수증서에 의한 유언의 검인을 함에 있어서는 가정법원은 유언의 방식에 관한 모든 사실을 조사하여야 한다(가사소송규칙 제85조 제1항). 먼저 유언서가 구수증서인지 여부를 살펴야 하고, 그 검인절차가 법정기간을 준수하였는지 여부를 심리하여야 한다. 직권으로 사실조사 및 필요하다고 인정되는 증거조사를 하여 그 유언이 유언자의 진의에 의한 것인지 여부를 판단하여야 한다.

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

한편, 유언의 실제적 효력에 관하여 판례⁵¹¹⁾는 “유언취지의 구수’라 함은 말로써 유언의 내용을 상대방에게 전달하는 것을 뜻하는 것이므로, 증인이 제3자에 의하여 미리 작성된, 유언의 취지가 적혀 있는 서면에 따라 유언자에게 질문을 하고 유언자가 동작이나 간략한 답변으로 긍정하는 방식은, 유언 당시 유언자의 의사능력이나 유언에 이르게 된 경위 등에 비추어 그 서면이 유언자의 진의에 따라 작성되었음이 분명하다고 인정되는 등의 특별한 사정이 없는 한 민법 제1070조 소정의 유언취지의 구수에 해당한다고 볼 수 없다.”고 하였다.

아. 심 판

심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조).

검인의 심판이 확정되면 구수증서에 의한 유언은 성립요건이 구비되고 유언서 작성시로 소급하여 성립한다. 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다.

자. 심판종료 후의 절차(즉시항고)

가정법원은 검인함에 있어서 유언검인의 청구를 기각한 심판에 대해서는 청구인 및 다른 청구권자가 즉시항고를 할 수 있고, 유언검인의 심판에 대하여는 이해관계인이 즉시항고를 할 수 있다.

511) 대법원 2006. 03. 09. 선고 2005다57899 판결; 대법원 2007. 10. 25. 선고 2007다51550, 51567 판결.

민법 제1070조의 구수증서에 의한 유언의 검인에 대하여 즉시항고를 할 수 있는 이해관계인이라 함은 상속인 기타 검인에 의하여 직접 그 권리가 침해되었다고 객관적으로 인정되는 자를 의미한다. 예컨대 갑은 직계비속이 없고 남편도 일찍 사망하여 부담 있는 유증을 내용으로 하는 유언을 한바, 그의 형제자매와 8촌 이내의 방계혈족이 순차 그 상속인이 되는 것이므로 갑의 망 부의 동생은 유언자의 상속인이 될 수 없고, 그가 수증자나 유언집행자도 아니며 위 유증에 의하여 그 수증자로부터 금 20,000,000원을 지급받게 됨으로써 오히려 이익을 받게 될 지위에 있을 뿐이라면 위 유언의 검인에 대한 이해관계인이라고는 볼 수 없으므로 그가 제기한 항고는 부적법하다.⁵¹²⁾

512) 대법원 1990. 02. 12. 자 89스19 결정.

제4관 유언의 증서 또는 녹음의 검인

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.41), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

유언의 증서나 녹음을 보관하는 자 또는 이를 발견한 자는 상속개시(유언자의 사망)를 안 후 지체 없이 가정법원에 제출하여 그 검인을 청구하여야 한다(민법 제1091조 1항). 여기서 유언의 증서는 앞서 설명한 유언의 방식 중에서 자필증서 및 비밀증서를 말한다. 따라서 공정증서에 의한 유언이나 구수증서에 의한 유언은 여기의 검인 대상에 속하지 않는다(민법 제1091조 제2항).

2. 심판청구절차

가. 청구권자

청구권자는 유언의 증서나 녹음을 보관하고 있는 자 또는 이를 발견한 자이다. 이들은 동시에 청구의무자이기도 하다. 이 의무를 해태한 때에는 상속인에 대한 불법행위가 성립할 수 있고 유언서의 은닉에 해당되어 상속결격의 사유가 될 수 있다(민법 제1004조 5호)

나. 심판청구서 작성방법

(1) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(2) 청구취지 기재례

유언자 ○○○는 20○○. 3. 5. 별지와 같은 내용의 유언을 하였음을 검인한다(또는 확인한다).
라는 심판을 구합니다.

다. 첨부서류

가족관계증명서(유언자, 청구권자 등) 1통, 기본증명서(유언자, 청구권자 등) 1통, 제적

등본 및 말소된 주민등록표등본(유언자), 주민등록표등본(상속인) 각 1통, 유언증서 1통, 기타서류 등이 필요하다. 검인을 청구함에는 그 유언의 증서나 녹음대를 제출하여야 한다.

라. 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 검인 대상이 되는 유언서 녹음대마다 1개의 청구로 본다. 따라서 검인대상이 되는 유언대 녹음대가 둘이면 10,000원을 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다. 송달료는 청구인의 수(상속인 포함)×5,200원×6회분이다. 송달료는 법원 구내은행에서 송달료예납 납부서를 작성하여 납부하면 된다.

마. 청구서 제출(관할법원)

피상속인의 마지막 주소지에 제출한다. 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원소재지의 가정법원에 제출한다. 검인의 청구는 유언자의 사망 후 지체 없이 하여야 한다.

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다.

[서식] 유언검인심판청구서

유언검인심판청구

청 구 인(상속인) 이 ○ 호 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(유언자) 이 ○ 화

주민등록번호

마지막 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

유언자 망 이○화가 20○○. 5. 25.자 작성한 자필증서에 의한 별지 유언서를 검인한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 청구인은 유언자의 장남이며 본 건 유언증서의 보관자인 바, 망 유언자 이○화는 인천 ○○구 ○○동 114 소재 답 2,212㎡, 같은 동 95의1 소재 대지 192㎡, 같은 동 95의 2 소재 전 516㎡ 및 위 지상 미등기건물을 소유하고 있었습니다.
2. 유언자는 20○○. 10.경부터 ○○시립병원에 2개월 간 입원하였다가 ○○병원에서 종합진단결과 간암으로 판명되자, 그 후 인천 ○○구 ○○동 소재 ○○병원에서 입원하고 있던 중 자신의 죽음을 예상하고 20○○. 1. 9. 04:00경 자녀(2남2녀)들을 위 ○○병원 입원실에 불러 참석한 가운데, 망인이 미리 준비한 양면패지(세로 24.6센티미터×가로 17.2센티미터)의 상단에 프로스펜으로 한글로 사후유서라고 쓰고 유언내용으로 “현 재산에 대하여 추후 내가 세상을 떠나는 즉시 바로 시행하라면서 청구 외 1을(장녀) 유언집행자로 지정하고, 청구인(장남)에게 최하

100,000,000원에서 200,000,000원을 지급하며, 장녀와 차녀에게는 각 50,000,000원씩, 그리고 부동산은 7분의 3을 큰 아들인 청구인이, 7분의 2를 작은 아들 각 몫으로 분배한다”는 취지로 직접 유서의 내용을 쓰고 말미에는 자필로 유언서 작성일(20〇〇. 1. 9.)과 위 망인의 성명을 한자로 기재하고 서명한 다음 주소는 기재하지 않은 상태에서 위 병원 간호원실에서 가져온 인주를 망인의 오른손 엄지손가락에 묻혀 지장을 찍어 유서를 작성하여 장남에게 보관토록 하였습니다.

3. 그 후 유언자는 20〇〇. 3. 25. 사망하였으므로 이 건 유언증서의 검인을 구하고자 청구취지와 같은 심판을 구하기 위하여 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 유언자(사건본인)의 기본증명서, 가족관계증명서, 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 가족관계증명서, 주민등록등(초)본(청구인, 상속인) 각 1통
1. 유언증서 사본 1통
1. 상속인 목록 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 이 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

[서식] 유언녹음검인청구서

유언녹음검인청구

청 구 인(상속인) 이 ○ 호 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(유언자) 이 ○ 화

주민등록번호

마지막 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

유언자 망 이○화가 20○○. 4. 5.자 한 녹음에 의한 별지 유언을 검인한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

1. 피상속인 망 이○화는 슬하에 2남 1녀를 두고 처가 먼저 사망하여 혼자 자녀들을 양육하여 열심히 살아왔으나 회사 출장 시 예견치 못한 교통사고로 치료를 받던 중 합병증이 발생하여 거동이 부자연스럽고 병이 점차 악화되어 어느 병이 호전되면 유언공증을 할 마음을 가지고 있었습니다.
2. 그러던 중 병세가 악화되고 도저히 움직일 수 없어 유언자는 20○○. 1. 23. 처와 가족들이 모인 앞에서 변호사 2명을 증인으로 하여 그들의 입회하에 유언취지를 말하고 유언을 녹음하고 유언의 정확함과 그 성명을 구술하였습니다.

3. 그 후 유언자는 20〇〇. 3. 25. 사망하였으므로 이 건 유언녹음의 검인을 구하고자 청구취지와 같은 심판을 구하기 위하여 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 유언자(사건본인)의 기본증명서, 가족관계증명서, 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 가족관계증명서, 주민등록등(초)본(청구인, 상속인) 각 1통
1. 녹음테이프
1. 상속인 목록 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 이 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

바. 심리절차

(1) 직권탐지주의와 법원의 재량

가정법원은 공동상속인지, 그중 수인이 한정승인을 한 경우인지, 누구를 상속재산관리인으로 선임할 것인지의 여부를 심리하여 공동상속재산관리인을 선임한다.

(2) 검인기일의 지정·소환·참여·통지

검인청구가 접수되면 가정법원은 검인기일을 지정하여 검인을 행한다. 유언증서가 봉인되어 있는 때는 이를 개봉하여 검인하여야 하고, 이때에는 개봉기일과 검인기일을 같은 날로 지정한다. 검인기일에는 청구인을 소환하고 상속인 기타 이해관계인에게도 그 기일을 통지하여 참여의 기회를 주는 것이 바람직하다. 봉인된 유언의 증서나 녹음을 개봉할 때에는 유언자의 상속인 그 대리인 기타 이해관계인의 참여가 있어야 한다(민법 제1092조). 따라서 이를 개봉하고자 할 때에는 유언자의 상속인 또는 그 대리인을 소환하고 기타 이해

관계인에게 통지하여야 한다(가사소송규칙 제86조 제2항).

(3) 검인기일의 실시

가정법원은 기일에서 유언의 증서나 녹음을 검인하고 검인함에 있어서는 유언의 방식에 관한 모든 사실을 조사하여야 한다(가사소송규칙 제86조 제3항). 유언의 방식에 관한 모든 사실이란 민법이 정한 유언의 방식의 구비 여부의 판정에 필요한 일체의 사실을 뜻한다.

유언서의 검인은 유언의 방식에 관한 일체의 사실을 조사하여 유언서 자체의 상태를 확정하기 위한 것이지 유언의 효력을 판단하기 위한 것이 아니므로 검인청구가 된 유언서가 민법이 정한 방식에 따르지 아니한 것이라고 하더라도 그 청구를 각하할 수 없고, 반드시 검인을 하여야 한다.⁵¹³⁾ 그리고 유언의 증서나 녹음의 개봉과 검인에 관하여는 조서를 작성하여야 한다(동규칙 제87조 제1항). 유언증서의 개봉과 검인을 한 때에는 가정법원은 출석하지 아니한 상속인, 그 밖에 유언의 내용에 관계있는 자에게 그 사실을 고지하여야 한다(동규칙 제88조). 검인을 마친 후에는 가정법원의 법원사무관 등은 유언의 증서나 녹음대의 원본에 “2002 3. 5. 검인필”이라고 기재하고 기명한 후 직인을 날인하여 청구인에게 반환하여야 한다.

(4) 사건관계인의 심문 등

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

사. 심 판

명문의 규정이 없으나 공동상속재산관리인선임심판은 청구인 외에, 선임된 재산관리인과 다른 공동상속인 전원에게 고지하여야 할 것이다. 심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조).

검인은 유언의 증서나 녹음의 방식과 내용을 객관적으로 확인한 것이지 그 효력유무를 판단하는 것은 아니다. 또 검인이 유언의 성립요건이나 효력발생요건도 아니다. 따라서 검인이 있더라도 그 유언의 무효를 주장할 수 있다.

아. 심판종료 후의 절차(불복 및 취하)

검인에 대하여는 불복할 수 없다. 유언의 증서나 녹음에 대한 검인의 청구는 그 보관자

513) 대법원 1980. 11. 19. 자 80스23 결정.

또는 발견자의 권리이자 의무이므로 그 청구를 취하할 수 없다.

제5관 유언증서의 개봉

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.42), 라류 가사비송사건]

1. 의 의

봉인이 되어 있는 유언서를 가정법원에서 개봉할 때에는 유언자의 상속인, 그 대리인, 기타 이해관계인의 참여가 있어야 한다(민법 제1092조). 봉인된 유언증서라 함은 그 내용을 외부에서 확인할 수 없도록 봉하고 밀봉한다는 뜻의 날인이 되어 있는 것을 말한다. 따라서 단순히 봉투 등에 들어 있는 것만으로는 봉인된 것이라고 할 수 없다. 민법 제1092조에서 규정하는 유언증서의 개봉절차는 봉인된 유언증서의 검인에는 반드시 개봉이 필요하므로 그에 관한 절차를 규정한 데에 지나지 아니하므로, 적법한 유언은 이러한 개봉절차를 거치지 않더라도 유언자의 사망에 의하여 곧바로 그 효력이 생기는 것이며, 개봉절차의 유무에 의하여 유언의 효력이 영향을 받지 아니한다.⁵¹⁴⁾

2. 개봉절차

가. 개봉장소

가정법원에서 하여야 한다.

나. 개봉기일의 지정·소환·통지

가정법원이 봉인된 유언증서를 개봉할 때에는 유언자의 상속인, 그 대리인 기타 이해관계인의 참여가 있어야 한다(민법 제1092조). 따라서 가정법원이 봉인된 유언증서를 개봉하고자 할 때에는 미리 그 기일을 지정하여 유언자의 상속인, 그 대리인을 소환하고, 그 밖의 이해관계인에게 통지하여야 한다(가사소송규칙 제86조 제2항). 봉인된 유언증서의 개봉은 그 유언증서의 검인절차의 일부를 이루는 것이므로 개봉기일과 검인기일을 같은 날로 지정하는 것이 보통이다. 소환을 받은 상속인 또는 그 대리인이 정당한 이유 없이 출석하지 아니한 때에는 가정법원은 50만 원 이하의 과태료를 처할 수 있고 구인할 수 있다(가사소송법 제66조). 기타 이해관계인은 개봉 및 검인에 참여할 수 있으나 그 의무가

514) 대법원 1998. 06. 12. 선고 97다38510 판결.

있는 것은 아니다.

다. 개봉의 실시

개봉은 봉인을 제거하고 내용물을 확인하는 방법으로 실시한다.

라. 개봉사실의 고지

가정법원이 봉인된 유언증서를 개봉한 때에는 개봉기일에 출석하지 아니한 유언자의 상속인 기타 유언의 내용에 관계있는 자에게 그 사실을 고지하여야 한다(가사소송규칙 제88조).

3. 검인·개봉절차를 거치지 아니한 유언증서의 효력

민법 제1091조에서 규정하고 있는 유언증서에 대한 법원의 검인은 유언증서의 형식·태양 등 유언의 방식에 관한 모든 사실을 조사·확인하고 그 위조·변조를 방지하며, 또한 보존을 확실히 하기 위한 일종의 검증절차 내지는 증거보전절차로서, 유언이 유언자의 진의에 의한 것인지 여부나 적법한지 여부를 심사하는 것이 아님은 물론 직접 유언의 유효 여부를 판단하는 심판이 아니고, 또한 민법 제1092조에서 규정하는 유언증서의 개봉절차는 봉인된 유언증서의 검인에는 반드시 개봉이 필요하므로 그에 관한 절차를 규정한 데에 지나지 아니하므로, 적법한 유언은 이러한 검인이나 개봉절차를 거치지 않더라도 유언자의 사망에 의하여 곧바로 그 효력이 생기는 것이며, 검인이나 개봉절차의 유무에 의하여 유언의 효력이 영향을 받지 아니한다.⁵¹⁵⁾

515) 대법원 1998. 06. 12. 선고 97다38510 판결.

[서식] 유언증서의 개봉 및 검인신청서

유언증서의 개봉 및 검인신청

청 구 인(상속인) 이 ○ 호 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(유언자) 이 ○ 화

주민등록번호

마지막 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

유언자 망 이○화가 20○○. 5. 25.자 작성한 자필증서에 의한 유언서를 개봉하고
검인한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 이 유

1. 피상속인 망 이○화는 슬하에 2남 1녀를 두고 처가 먼저 사망하여 혼자 자녀들을 양육하여 열심히 살아왔으나 추후 자녀들을 위해 현재 소유하고 있는 부동산을 골고루 나누어 주기 위해 여러 차례 유언을 하겠다고 말을 해 오던 중 회사 출장시 예견치 못한 교통사고로 치료를 받던 중 합병증 유발로 20○○. 10. 30. 사망하였습니다.
2. 피상속인의 장례를 치르고 유품을 정리하던 중 예견했던 대로 봉투의 앞면에는 ‘유서(遺書)’라고 한자로 기재하고, 봉투 뒷면에는 자신의 주소인 ‘서울 ○○구 ○○로 10을’ 자필로 기재한 다음 이를 각기 봉함’이라고 기재한 유언서를 발견하였습니다.

3. 따라서 유언서의 모든 사실을 조사 확인하고 그 위조·변조를 방지하기 위해 청구 취지와 같은 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

1. 유언자(사건본인)의 기본증명서, 가족관계증명서, 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
1. 가족관계증명서, 주민등록등(초)본(청구인, 상속인) 각 1통
1. 유언증서 사본 1통
1. 상속인 목록 1통
1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 이 ○ 호 (인)

]

,

서울가정법원 귀중

제6관 유언집행자의 선임 및 그 임무에 관한 처분

[가사소송법 제2조 제1항 2.가.43), 라류 가사비송사건]

1. 유언집행자의 자격 및 권리와 의무

가. 유언집행자의 자격

제한능력자와 파산선고를 받은 자는 유언집행자가 되지 못한다(민법 제1098조). 유증의 실현은 유언의 이행행위에 지나지 아니하여 수증자의 집행행위를 자기계약으로 볼 수 없으므로 수증자에게 유언 집행 자격이 없다.⁵¹⁶⁾ 공증인은 촉탁 받은 사항에 관하여 이해관계가 있을 때에는 그 직무를 행할 수 없기 때문에(공증인법 제21조 제3호) 공정증서유언서를 작성한 경우 그 공증유언의 집행자가 될 수 없다. 친생부인과 인지의 경우 유언집행자의 직무가 상속인의 이해와 상반되므로 상속인은 유언집행자가 될 수 없다고 하여야 한다.⁵¹⁷⁾ 민법 제1095조는 유언자가 유언집행자의 지정 또는 지정위탁을 하지 아니하거나 유언집행자의 지정을 위탁받은 자가 위탁을 사퇴한 때에 한하여 적용되는 것이므로, 유언자가 지정 또는 지정위탁에 의하여 유언집행자의 지정을 한 이상 그 유언집행자가 사망·결격 기타 사유로 자격을 상실하였다고 하더라도 상속인은 민법 제1095조에 의하여 유언집행자가 될 수는 없다. 즉, 유증 등을 위하여 유언집행자가 지정되어 있다가 그 유언집행자가 사망·결격 기타 사유로 자격을 상실한 때에는 상속인이 있더라도 유언집행자를 선임하여야 하는 것이므로, 유언집행자가 해임된 이후 법원에 의하여 새로운 유언집행자가 선임되지 아니하였다고 하더라도 유언집행에 필요한 한도에서 상속인의 상속재산에 대한 처분권은 여전히 제한되며 그 제한 범위 내에서 상속인의 원고적격 역시 인정될 수 없다.⁵¹⁸⁾

나. 유언집행자의 법적지위

유언집행에 필요한 한도에서 유언집행자에게 상속재산에 대한 관리처분권이 인정되므로, 유언집행자의 권한과 충돌하는 상속인의 처분권은 제한되어야 한다. 민법은 이에 대한 규정이 없으므로 상속인이 이를 위하여 처분행위를 하여도 그 처분을 무효라고 할 수 없으며, 단지 상속인에게 책임을 추궁할 수 있다고 하여야 할 것이다.⁵¹⁹⁾

516) 서울지방법원 1995. 04. 28. 자 94파8391 결정.

517) 박윤직, 앞의 책(상속법), 269면; 송덕수, 앞의 책, 1971면; 그러나 반대 견해가 있다[김주수·김상용, 앞의 책, 726면].

518) 대법원 2010. 10. 28. 선고 2009다20840 판결.

다. 유언집행자의 권리와 의무

유언집행자는 취임 후 즉시 그 임무를 이행하여야 한다.

(1) 재산목록작성

유언집행자는 지체 없이 상속재산의 목록을 작성하여 상속인에게 교부하여야 한다(민법 제1100조 제1항).

(2) 관리·집행행위

또한 유증의 목적인 재산의 관리 기타 유언의 집행에 필요한 행위를 할 권리의무가 있다(민법 제1101조). 유증 목적물에 관하여 마쳐진, 유언의 집행에 방해가 되는 다른 등기의 말소를 구하는 소송에 있어서는 유언집행자가 이른바 법정소송담당으로서 원고적격을 가진다고 할 것이고, 유언집행자는 유언의 집행에 필요한 범위 내에서는 상속인과 이해상반되는 사항에 관하여도 중립적 입장에서 직무를 수행하여야 하므로, 유언집행자가 있는 경우 그의 유언집행에 필요한 한도에서 상속인의 상속재산에 대한 처분권은 제한되며 그 제한 범위 내에서 상속인은 원고적격이 없다.⁵²⁰⁾

(3) 상속인에 의한 상속재산 처분제한

유언집행자의 임무에 관한 처분은 가정법원이 직권으로 한다. 이해관계인 등의 청구가 있더라도 이는 직권발동을 촉구하는 의미만 있을 뿐이다. 이 처분은 유언집행자의 선임에 따른 부수처분이라고도 할 수 있으므로 별도로 사건번호를 부여하여 기록을 조제할 것은 아니다.

유언집행자의 임무에 관한 처분은 성질상 유언집행자의 선임과 동시에 할 수 있다고 생각되지만 유언집행자의 선임에 대하여는 그 선임된 자의 승낙의 통지를 필요로 하므로(민법 제1097조 제2항) 그 승낙의 통지가 있는 후에 유언집행자의 임무에 관한 처분을 하는 것이 바람직하다.⁵²¹⁾

(4) 공동유언집행

유언집행자가 수인인 경우에는 임무의 집행은 그 과반수의 찬성으로써 결정한다(민법

519) 박윤직, 앞의 책(상속법), 275면; 김주수·김상용, 앞의 책, 730면; 송덕수, 앞의 책, 1972면.

520) 대법원 2010. 10. 28. 선고 2009다20840 판결.

521) 법원행정처, 앞의 책, 427면.

제1102조 본문). 가부동수로 과반수를 얻을 수 없는 경우에는 이를 해임하여 새로 유언집행자를 선임한다(민법 제1106조, 제1096조). 그러나 보존행위에 대해서는 각 유언집행자는 단독으로 할 수 있다(민법 제1102조 단서).

수인의 유언집행자 중 1인만을 피고로 하여 유증의무 이행을 구하는 소송을 제기한 사안에서, 유언집행자 지정 또는 제3자의 지정 위탁이 없는 한 상속인 전원이 유언집행자가 되고, 유언집행자에 대하여 민법 제1087조 제1항 단서에 따라 유증의무의 이행을 구하는 것은 유언집행자인 상속인 전원을 피고로 삼아야 하는 고유필수적 공동소송이다.⁵²²⁾

(5) 유언집행자의 등기신청과 상속인과의 다툼

유증을 받은 자의 소유권보존(이전)등기신청절차 등에 관한 사무처리지침(대법원 등기예규 제1482호)에 의하면 유언집행자의 등기신청 시 자필 유언증서에 관한 검인조서를 첨부하도록 함과 아울러 검인조서에 검인기일에 출석한 상속인들이 “유언자의 자필이 아니고 날인도 유언자의 사용인이 아니라고 생각한다.”는 등 자필 유언증서의 진정성에 관하여 다투는 사실이 기재되어 있는 경우에는 위 상속인들이 “유언 내용에 따른 등기신청에 이의가 없다.”는 취지로 작성한 동의서와 인감증명서를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있다. 그런데 상속인들이 진술서의 작성을 거절하는 경우 어떻게 처리해야 하는가? 유언집행자가 자필 유언증서상 유언자의 자서와 날인의 진정성을 다투는 상속인들에 대하여 ‘유언 내용에 따른 등기신청에 이의가 없다’는 진술을 구하는 소는, 등기관이 자필 유언증서상 유언자의 자서 및 날인의 진정성에 관하여 심사하는 데 필요한 증명자료를 소로써 구하는 것에 불과하고, 민법 제389조 제2항에서 규정하는 ‘채무가 법률행위를 목적으로 한 때에 채무자의 의사표시에 갈음할 재판을 청구하는 경우’에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 위와 같은 소는 권리보호의 이익이 없어 부적법하다. 또한 유언집행자가 제기한 위와 같은 소를 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기에 대하여 상속인들의 승낙을 구하는 것으로 본다 하더라도, 포괄유증의 성립이나 효력발생에 상속인들의 승낙은 불필요하고, 부동산등기법 관련 법령에서 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기에 대하여 상속인들의 승낙이 필요하다는 규정을 두고 있지도 아니하므로, 이는 부동산등기법 관련 법령에 따라 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기를 마치는 데 있어 필요하지 아니한 제3자의 승낙을 소구하는 것에 불과하여 권리보호의 이익이 없다 할 것이어서 역시 부적법하다.

유언집행자로서는, 자필 유언증서상 유언자의 자서와 날인의 진정성을 다투는 상속인들이 유언 내용에 따른 등기신청에 관하여 이의가 없다는 진술서의 작성을 거절하는 경우에

⁵²²⁾ 대법원 2011. 06. 24. 선고 2009다8345 판결.

는 그 진술을 소로써 구할 것이 아니라, 그 상속인들을 상대로 유언효력확인 소나 포괄적 수증자 지위 확인의 소 등을 제기하여 승소 확정판결을 받은 다음, 이를 부동산등기규칙 제46조 제1항 제1호 및 제5호의 첨부정보로 제출하여 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청할 수 있다.⁵²³⁾

2. 지정유언집행자

유언자는 유언으로 유언집행자를 지정할 수 있고 그 지정을 제3자에게 위탁할 수 있다(민법 제1093조). 위탁을 받은 제3자는 그 위탁 있음을 안 후 지체 없이 유언집행자를 지정하여 상속인에게 통지하여야 하며 그 위탁을 사퇴할 때에는 이를 상속인에게 통지하여야 한다(민법 제1094조 제1항). 상속인 그 밖의 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 유언집행자를 지정할 것을 위탁받은 자에게 최고할 수 있다. 그 기간 내에 지정의 통지를 받지 못한 때에는 그 지정의 위탁을 사퇴한 것으로 본다(동조 제2항).

3. 법원에 의한 유언집행자의 선임

가. 의 의

유언집행자가 없거나 사망, 결격 기타의 사유로 없게 된 때에는 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 유언집행자를 선임하여야 한다(민법 제1096조 제1항). 유언집행자가 없거나 없게 된 때라는 것은 유언집행자의 지정이 없는 때뿐만 아니라 그 지정을 위탁받은 제3자가 유언집행자를 지정하지 않거나 지정유언집행자가 결격자인 때, 사퇴하거나 사망한 때 등을 포함한다.

나. 선임의 요건

유언집행자가 없거나 사망, 결격, 그 밖의 사유로 없게 된 때이어야 한다. 유언집행자 선임은 유언집행자가 전혀 없게 된 경우뿐만 아니라 유언집행자의 사망, 사임, 해임 등의 사유로 공동유언집행자에게 결원이 생긴 경우와 나아가 결원이 없어도 법원이 유언집행자의 추가선임이 필요하다고 판단한 경우에 이를 할 수 있다.⁵²⁴⁾

또한 유언집행자가 2인인 경우 그중 1인이 나머지 유언집행자의 찬성 내지 의견을 청취

523) 대법원 2014. 02. 13. 선고 2011다74277 판결.

524) 대법원 1995. 12. 04. 자 95스32 결정.

하지 아니하고도 단독으로 법원에 공동유언집행자의 추가선임을 신청할 수 있다.⁵²⁵⁾

‘유언집행자가 없는 때’라 함은 지정유언집행자 및 상속인인 유언집행자가 모두 처음부터 없는 때를 말한다. ‘사망, 결격, 그 밖의 사유로 없게 된 때’라고 함은 유언집행자가 사망, 결격, 그 밖의 사유로 없게 된 때, 즉 상속인인 유언집행자의 사망, 임무종료 전 지정·선임유언집행자의 사망, 유언집행자의 결격(지정·선임유언집행자 또는 상속인인 유언집행자가 파산하거나 무능력자로 된 때), 지정·선임유언집행자의 사퇴와 해임, 그 밖의 사유로 유언집행자가 없게 된 때를 말한다.

유언자가 유언집행자의 지정 또는 지정위탁을 하지 아니하거나 유언집행자의 지정을 위탁받은 자가 위탁을 사퇴한 때에 한하여 적용되는 것이고, 유언자가 지정 또는 지정위탁에 의하여 유언집행자의 지정을 한 이상 그 유언집행자가 취임의 승낙을 하였는지를 불문하고 사망·결격 기타 사유로 유언집행자의 자격을 상실한 때에는 민법 제1096조에 의하여 이해관계인이 법원에 유언집행자의 선임을 청구할 수 있다.⁵²⁶⁾

갑은 협의이혼 후 을과 재혼하였는데, 전처와의 사이에서 태어난 병을 유언집행자로 지정하여 병 등에게 재산 일체를 유증하는 내용의 유언공정증서를 작성한 후 사망 직전에 재산을 상속인들이 법정상속분대로 나누라는 내용의 녹음에 의한 유언을 한 사안에서, 공정증서에 의한 유언은 녹음에 의한 유언의 내용과 저촉되어 철회되었고, 녹음에 의한 유언을 통해 별도로 유언집행자를 지정하지 않았으므로, 병은 유언집행자라고 볼 수 없어 당사자적격이 없다.⁵²⁷⁾

유언집행자가 유언자의 사망 전에 먼저 사망한 경우와 같이 유언의 효력 발생 이전에 지정된 유언집행자가 그 자격을 상실한 경우에는 ‘지정된 유언집행자가 없는 때’에 해당하므로, 특별한 사정이 없는 한 제1095조가 적용되어 상속인이 유언집행자가 된다. 이러한 경우 상속인이 존재함에도 불구하고 법원이 제1096조 제1항에 따라 유언집행자를 선임할 수는 없다.⁵²⁸⁾

다. 심판청구절차

(1) 청구권자

상속인, 상속채권자, 유증을 받을 자, 상속인의 채권자 등과 같이 법률상의 이해관계를

525) 대법원 1987. 09. 29. 자 86스11 결정.

526) 대법원 2007. 10. 18. 자 2007스31 결정.

527) 대전지방법원 2015. 10. 14. 선고 2014가합106384 판결 : 항소.

528) 대법원 2018. 3. 29. 자 2014스73 결정.

가지는 자가 청구할 수 있다.

(2) 청구서 작성방법

(가) 청구방법

심판청구는 서면 또는 구술로 할 수 있다(가사소송법 제36조 제1항). 서면으로 할 경우 작성방법은 아래의 [서식]을 참조한다.

(나) 청구취지 기재례

유언자 망 정○○의 유언집행자로 서울 ○○구 ○○로 10, 김○○(주민등록번호)를 선임한다.

라는 심판을 구합니다.

유언자 망 정○○이 2010. 9. 30.에 한 유언의 집행자로 이○○(주민등록번호, 주소)을 선임한다.

라는 심판을 구합니다.

유언자 망 정○○이 공증인가 ○○종합법무법인 작성 2009년 증제1234호 공정증서로 한 유언의 집행자로 박○○(주민등록번호, 주소)을 선임한다.

라는 심판을 구합니다.

(3) 첨부서류

가족관계증명서 1통, 기본증명서1통, 유언증서, 기타 서류 등이 필요하다.

(4) 청구비용

라류 가사비송사건이므로 인지는 사건본인 1인당 5,000원의 인지를 붙여야 한다. 유언 집행자마다 1개의 청구로 본다. 따라서 유언집행자가 2명이면 10,000원의 인지를 첨부하여야 한다. 인지는 법원 구내우체국에서 구입한다. 송달료는 상속인의 수×5,200원×10회분이다. 송달료는 법원 구내은행에서 송달료예납납부서를 작성하여 납부하면 된다.

(5) 청구서 제출

가정법원 단독판사의 사물관할에 속한다. 피상속인의 마지막 주소지를 관할하는 가정법

원에 제출한다. 심판청구서 원본(법원용) 1통을 준비하여 직접 관할 가정법원에 제출하거나, 대리인에 의하여 제출할 수 있고 대리인에 의하여 제출할 경우 위임장 1통을 준비한다. 또한 우편 접수도 가능하다. 마지막 주소지가 외국인 경우에는 대법원소재지의 가정법원에 제출한다.

[서식] 유언집행자선임청구서

유언집행자선임청구

청 구 인(상속인) 이 ○ 호 (☎)

주민등록번호

주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동) (우편번호)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

사건본인(유언자) 이 ○ 화

주민등록번호

마지막 주소 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

등록기준지 서울 ○○구 ○○대로 ○○(○○동)

청 구 취 지

유언자 망 이○화의 유언집행 자로 장○수(주민등록번호 : , 주소 :)를 선임한다.

라는 심판을 구합니다.

청 구 이 유

1. 피상속인 망 이○화는 슬하에 2남 1녀를 두고 처가 먼저 사망하여 혼자 자녀들을 양육하여 열심히 살아왔으나 회사 출장 시 예견치 못한 교통사고로 20○○. 5. 25.자 갑자기 사망하였고, 유품을 정리하는 도중 유언서가 발견되었으나 유언집행자의 지정이 없었습니다.
2. 위와 같이 유언자의 유언을 집행할 자가 없으므로, 유언자의 장남이 책임자로

사료되어 그 집행을 위하여 청구취지 기재와 같은 심판을 구하기 위하여 이 건 청구에 이른 것입니다.

첨 부 서 류

- 1. 유언자(사건본인)의 기본증명서, 가족관계증명서, 말소된 주민등록등(초)본 각 1통
- 1. 가족관계증명서, 주민등록등(초)본(청구인, 상속인) 각 1통
- 1. 유언증서 사본 1통
- 1. 상속인 목록 1통
- 1. 납부서 1통

20〇〇. 6. .

위 청구인 이 ○ 호 (인)

서울가정법원 귀중

(6) 심리절차

누구를 유언집행자로 선임하느냐는 문제는 민법 제1098조 소정의 유언집행자의 결격사유에 해당하지 않는 한 당해 법원의 재량에 속한다고 한다.⁵²⁹⁾

라류 가사비송사건에서는 사건관계인의 심문이 필요한 것이 아니고(가사소송법 제45조), 서면심리에 의하는 것이 보통이다.

(7) 심 판

심판은 청구인에게 고지하여야 하고, 선임된 유언집행자에게 통지하여야 한다. 그 방법은 제한이 없지만 보통 심판서정본을 송달한다. 심판은 이를 받은 자가 고지받음으로써 효력을 발생한다(가사소송법 제40조). 심판확정에 의하여 당연히 유언집행자로서의 권리

529) 대법원 1995. 12. 04. 자 95스32 결정.

의무를 가지는 것이 아니고 선임된 자가 취임승낙이 있어야 한다. 따라서 심판서 정본을 받아본 선임된 유언집행자는 이러한 승낙이나 유언집행자가 되지 않겠다는 사퇴를 위한 통지를 가정법원에 하여야 한다. 심판은 형성력이 있고, 기판력은 없다. 상속인 기타 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간내에 승낙여부를 확답할 것을 선임된 유언집행자에게 최고할 수 있고, 선임된 유언집행자가 그 기간내에 최고에 대한 확답을 하지 아니한 때에는 그 취임을 승낙한 것으로 본다(민법 제1097조 제3항).

유언집행자는 유증의 목적인 재산의 관리 기타 유언의 집행에 필요한 모든 행위를 할 권리의무가 있으므로, 유증 목적물에 관하여 경료된, 유언의 집행에 방해가 되는 다른 등기의 말소를 구하는 소송에 있어서는 유언집행자가 이른바 법정소송담당으로서 원고적격을 가진다고 할 것이고, 유언집행자는 유언의 집행에 필요한 범위 내에서는 상속인과 이해상반되는 사항에 관하여도 중립적 입장에서 직무를 수행하여야 하므로, 유언집행자가 있는 경우 그의 유언집행에 필요한 한도에서 상속인의 상속재산에 대한 처분권은 제한되며 그 제한 범위 내에서 상속인은 원고적격이 없다고 할 것이다. 민법 제1103조 제1항은 “지정 또는 선임에 의한 유언집행자는 상속인의 대리인으로 본다.”고 규정하고 있으나, 이 조항은 유언집행자의 행위의 효과가 상속인에게 귀속함을 규정한 것이지, 유언집행자의 소송수행권과 별도로 상속인 본인의 소송수행권도 언제나 병존함을 규정한 것은 아니다.⁵³⁰⁾

(8) 심판종료 후의 절차(즉시항고)

선임청구를 기각한 심판에 대하여는 이해관계인이 즉시항고를 할 수 있고(가사소송규칙 제27조), 유언집행자를 선임한 심판에 대하여는 이해관계인이 즉시항고를 할 수 있다(동법 제84조 제1항)

4. 유언집행자의 임무에 관한 처분

가. 의 의

유언집행자는 취임 후 즉시 그 임무를 이행하여야 한다. 즉, 지체 없이 상속재산의 목록을 작성하여 상속인에게 교부하여야 한다(민법 제1100조 제1항). 또한 유증의 목적인 재산의 관리 기타 유언의 집행에 필요한 행위를 할 권리의무가 있다(민법 제1101조). 그리고 법원이 유언집행자를 선임한 경우에는 그 임무에 관하여 필요한 처분을 명할 수 있다(민법 제1096조 제2항).

530) 대법원 2001. 03. 27. 선고 2000다26920 판결.

유언집행자가 수인인 경우에는 임무의 집행은 그 과반수의 찬성으로써 결정한다(민법 제1102조 본문). 가부동수로 과반수를 얻을 수 없는 경우에는 이를 해임하여 새로 유언집행자를 선임한다(민법 제1106조, 제1096조). 그러나 보존행위에 대해서는 각 유언집행자는 단독으로 할 수 있다(민법 제1102조 단서).

나. 절차의 개시

유언집행자의 임무에 관한 처분은 가정법원이 직권으로 한다. 이해관계인 등의 청구가 있더라도 이는 직권발동을 촉구하는 의미만 있을 뿐이다. 이 처분은 유언집행자의 선임에 따른 부수처분이라고도 할 수 있으므로 별도로 사건번호를 부여하여 기록을 조제할 것은 아니다.

유언집행자의 임무에 관한 처분은 성질상 유언집행자의 선임과 동시에 할 수 있다고 생각되지만 유언집행자의 선임에 대하여는 그 선임된 자의 승낙의 통지를 필요로 하므로(민법 제1097조 제2항) 그 승낙의 통지가 있는 후에 유언집행자의 임무에 관한 처분을 하는 것이 바람직하다.⁵³¹⁾

다. 처분의 내용

가정법원이 할 처분의 내용에는 유언의 집행에 필요한 것인 한 아무런 제한이 없다.

531) 법원행정처, 법원실무제요[가사(Ⅱ)], 430면.